노동시장 개혁의 주요 쟁점 점검

- 취업규칙변경 및 통상해고 지침을 중심으로 -

일시 2016년 1월 25일 (월) 14:00~16:20

장소 전경련회관 컨퍼런스센터 2층 사파이어룸

keri 한국경제연구원

| 한국경제연구원 대외세미나 |

노동시장 개혁의 주요 쟁점 점검

- 취업규칙변경 및 통상해고 지침을 중심으로 -

■ 일시: 2016년 1월 25일(월) 14:00~16:20

■ 장소: 전경련회관 컨퍼런스센터 2층 사파이어룸

한국경제연구원
KOREA ECONOMIC RESEARCH INSTITUTE

PROGRAM

시 간	내 용
13:30~14:00	등 록
14:00~14:10	개회사 권태신 (한국경제연구원 원장)
14:10~15:10 [60′]	**발제 1 취업규칙 불이익변경 법리의 쟁점과 과제** 이상희 (한국산업기술대학교 지식융합학부 교수) **발제 2 직무수행능력을 이유로 한 해고의 정당성** 이상익 (국제공인노무사사무소 공인노무사)
15:10~16:20 [70′]	**종합토론** 좌장 김영문 (전북대학교 법학전문대학원 교수) 토론 김희성 (강원대학교 법학전문대학원 교수) 박우성 (경희대학교 경영대학 교수) 오계택 (한국노동연구원 임금직무혁신센터 소장) 이철행 (전국경제인연합회 고용복지팀 팀장) 홍준호 (김앤장 법률사무소 변호사) (가나다順)
16:20	폐 회

발제 1

취업규칙 불이익변경 법리의 쟁점과 과제

이 상 희 (한국산업기술대학교 지식융합학부 교수)

KERI 대외세미나

2016.1.25.

취업규칙 불이익변경 법리의 쟁점과 과제

이상희

한국산업기술대학교

목 차

I. 문제와 과제

II. 취업규칙 불이익변경 법리 현황

III. 정부 지침개정 초안 내용과 평가

IV. 취업규칙 불이익변경제도의 비교법적 검토

V. 결론 및 정책제언

2

I 문제와 과제

3

1. 정년연장에 왜 임금피크제가 따라 오는가?

우리나라 정년연장의 파급력 때문:
- 근속연수에 비례하는 연공임금체계
- 정년연장으로 임금도 상승하여 생산성과 괴리?

심한 연공임금체계 보유 때문:
- 연공임금체계는 어느 국가이든 조금씩 있음
- 일본과 한국은 유별나게 심한 연공성 보유
- 특히 일본보다 우리나라가 더 심하고,
- 단순제조업에서도 더 심함

4

2. 우리나라에서 임금피크제 등장 심화 원인?

최근 임금상승 요인:
- 정기상여금 등 통상임금 소송
- 60세 정년연장
- 조만간 근로시간단축 영향

단기 임금상승과 연공임금체계로 과한 임금조정 필요:
- 단기적 대증요법: 임금피크제
- 중장기적 대응체제: 임금체계 개편

5

3. 임금피크제와 취업규칙 불이익변경제도

취업규칙 작성 변경시:
- 근로자 집단의 회의체에 의한 의견청취의무

취업규칙 불이익변경시:
- 근로자 집단의 회의체에 의한 동의를 득할 의무
- 단, 사회통념상 합리성이 있는 경우 예외

임금피크제 등이 취업규칙 불이익변경 해당시:
- 노조 등 근로자집단의 동의를 득하기 거의 불가능

➢ 취업규칙 불이익변경법리가 임금피크제의 장애!

6

4. 정년연장과 임금피크제의 불이익변경?

고령자고용촉진법 제19조의2:
- 정년연장 사업의 노사에게 사업의 여건에 따라 임금체계 개편 등 필요한 조치를 할 의무 부과

제19조의2의 존재와 과제:
- 임금체계 개편 의무화, 9.15 노사정합의를 강조하면 임금피크가 불이익변경이라도 동의에 갈음할만한 사회통념상 합리성 인정으로 동의 없이 변경 가능한지가 쟁점?

7

5. 정년연장과 임금피크등 임금체계 개편 룰?

고령자고용촉진법 제19조의2, 기타 9.15 노사정합의에 근거한 임금피크 등 임금체계 변경 가능성 고조:
- 현행 취업규칙 불이익변경 룰에 맞추어 변경토록 사업장 혼란 예방 의무
- 특히 사회통념상 합리성 인정 기준에 대한 기존 판례 법리등을 명확화(9.15합의) 등이 필요

➢ 종전 취업규칙 해석 및 운영지침('09.4.24) 개정(안) 등장을 둘러싼 과도한 갈등과 과제 해법 모색 필요

8

II

취업규칙 불이익변경법리 현황

9

1. 관련 규정(근로기준법 제9장)

취업규칙 작성 신고 의무: 임금의 결정 계산 사항 (임금피크제와 같은 내용을 포함) 등을 작성(제93조 각호)

취업규칙 작성 변경 절차:
- 작성 변경시 과반수 근로자집단의 회의체에 의한(판례) 의견청취 의무(제94조 본문)
- 불리한변경시 그 동의를 얻을 의무(제94조 단서)

➢ 제94조 단서의 준수가 어렵고 경직성 문제 제기

10

2. 취업규칙 불이익변경 관련 판례 규범

불리한 변경 의미: 종전보다 근로조건을 낮추거나 복무 규율 강화하는 것

유불리 판단기준(판례):
- 변경 조건이 적용 전체 근로자 각각의 개별적 입장의 유불리 여부로(유불리 집단규모와 관계 없이) 판단
- 근로자 1인에게 유불리가 섞인 경우 변경내용의 대가 관계나 연계성있는 제반상황을 종합적으로 고려하여 판단

11

2-1. 불이익변경 판례 규범

사회통념상 합리성 판단 기준(판례):
불리한 변경이라도 사회통념상 합리성이 있으면 동의를 얻지 못하더라도 유효
- 불리한 변경으로 입게 되는 불이익 정도
- 변경의 필요성 내용과 정도
- 변경후 대상조치 등 다른 근로조건 개선상황
- 노동조합과 교섭경위 등
- 동종사항에 관한 국내의 일반적인 상황 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 함

12

3. 정년연장시 임금피크등의 사회통념상 합리성?

판례기준상 사회통념상 합리성에 정년연장시 임금피크 포함 여부가 관심
- 정년연장등에 따른 임금피크 등 임금체계 개편 필요성
- 고령자고용촉진법 제19조의2 노사의 책무
- 9.15합의 등

➢ 사회통념상 합리성 인정 기대 가능 요소로 현장 혼란?

13

III 정부 지침 개정 초안의 내용과 평가

14

1. 개정 배경

정년연장에 따른 노사공동책무인 임금체계개편 규정 (고령자고용촉진법 제19조) 실행 가능성 고조

산업현장의 임금체계개편 등 취업규칙 변경의 적법성 심사 등 정년연장의 안정적 정착 지원

15

2. 개정 기본원칙

취업규칙 작성 변경 제도 전반의 기준과 절차 제시

법령과 판례의 법리에 근거해서 마련
- 사회통념상 합리성도 법령 판례법리에 근거하여 마련

정년연장과 조화 이루는 임금체계 개편 책무가 있음을 적시

➢ 법령과 판례 범위내의 기준 제시
➢ 임금체계 개편 책무는 입법 취지 밝힘

16

3. 정년연장시 임금피크제의 변경 판단

임금 감액 조정 수반 임금피크제 도입은 불리한 변경

단 사회통념상 합리성 적용 판단을 원칙적인 기준으로 제시:
- 판례가 제시하는 요소의 기준
- 그간의 임금피크제와 임금체계 개편 관련 판례를 소개 현장기준에 참고

17

4. 평가

원칙적인 기본 판단 기준 제시

기존 법령과 판례법리 내의 기준 제시

정년연장과 임금피크 등 임금체계 개편의 사회통념상 합리성 인정기준도 판례법리 내 기준 제시

➢ 기존의 룰의 변화가 없음에도 관련 갈등을 고려하면 너무 비싼 대가를 치룸?

18

IV 취업규칙 변경제도의 비교법적 검토

19

1. 독일 종업원평의회제도(권혁, 2014)

사업장내 평의회 근로조건 변경절차의 다양성:
- 공동결정권(사규, 임금, 근로시간 등), 동의거절권 (배치전환 등), 거부권(정리해고계획 등), 자문권 (노무관리 현안사항 등), 협의권(교육훈련사항 등), 통지권(외부인력활용 계획 등)

➢ 절차 주체: 노동조합이 아닌 종업원평의회
➢ 주요 근로조건 변경에 강한 결정참여권

20

2. 일본 취업규칙제도

불리한 변경시 근로자 동의를 얻어야 함
- 종전에는 판례법리를 통해 규율, 사회통념상 합리성 기준도 판례법리 통해 형성(우리나라에 영향)
- 2007년 노동계약법 제9조(동의), 제10조(사회통념상 합리성 기준)에 기존 판례법리를 명문화

➢ 동의 주체가 근로자 집단이 아니라 개별근로자
➢ 근로자집단의 동의는 사회통념상 합리성 고려 요소
➢ 판례를 법령으로 체계화하여 취업규칙 변경 룰을 안정화

21

3. 비교 검토

독일과 비교:
- 공동결정에 비해 변경 방식은 유연할 수 있음
- 기업별 노사관계 체제상 사업장내 노동조합에 의한 의사결정(동의)의 경직성이 있음

일본과 비교:
- 동의 주체가 근로자이고, 근로자 집단의 동의는 사회통념상 합리성 고려 요소
- 사실상 불가능한 근로자 집단의 동의만 요구하는 우리보다 유연

➢ 비교적 불이익변경이 어려운 변경시스템으로 평가

22

V 결론 및 정책 제언

23

결론

- 정년연장 등 최근의 임금급증 요인을 고려하면 임금피크 등 임금체계 개편은 필요
- 정부 취업규칙 해석 및 운영 지침 개정은 성질상 기존 판례법리를 뛰어 넘을 수 없다는 한계가 있음
- 정부 지침 개정을 둘러싼 지나치게 불필요한 비용을 지불하고 있음에 유의

24

정책 제언

- 지침보다는 법령을 통한 취업규칙 변경 룰을 명확히 하는 것이 법적안정성에서 유리
- 비교법적으로 경직적인 취업규칙 변경 룰을 유연하게 개선할 필요가 있음
- 다만 입법여건 등 입법의 경제적 효율성을 고려하면 사회통념상 합리성 인정의 유연성 제고 방안이 적합
- 일본 판례중 정년전의 임금피크제 합리성 인정사례는 거의 없지만, 우리 정년연장이 일본보다 단기에 시행된 점, 연공성도 일본보다 심한 점, 고령자고용촉진법 제19조의2 등을 고려하면 인정 가능 고조도 전망

25

감사합니다

발제 2

직무수행능력을 이유로 한 해고의 정당성

이 상 익 (공인노무사, 국제공인노무사사무소)

직무수행능력을 이유로 한 해고의 정당성[1)]

- 관련 쟁점에 대한 판례 고찰 -

이상익 (공인노무사, 국제공인노무사사무소)

1. 들어가며
2. 직무수행능력 부족에 대한 판단
3. 인사고과의 합리성과 공정성
4. 개선 기회 부여
5. 나오며

1. 들어가며

○ 근로기준법 제23조 제1항에 따라 사용자가 근로자를 해고하려면 '정당한 이유'가 있어야 하며, 이는 통상해고(일반해고), 징계해고, 정리해고(근로기준법 제24조) 모두에 해당됨.

○ 판례는 통상해고와 일반해고, 징계해고라는 용어를 사용하고 있으면서도 명시적으로 통상해고, 일반해고, 징계해고의 개념을 언급하고 있지는 않으나, 종전 직책이 폐지되었음에도 근로자가 다른 업무에서는 근무하지 않겠다는 의사를 명백히 표시하여 해고한 것은 정리해고가 아닌 통상해고라고 하고(대판 1991.9.24, 91다13533), 해고의 사유가 징계해고 사유와 통상해고 사유 모두에 해당되는 경우에는 징계 절차를 밟아야 한다고 함(대판 1994.10.25, 94다25889). 하급심 판례 중에는 일반해고라는 용어를 사용하면서 이를 징계해고와 구분하여 "사용자는 단체협약의 명시적인 규정에 반하거나 이에 저촉되지 아니하는 한 취업규칙으로 해고 등 징계사유나 일반해고 사유를 규정하여 그 해고 사유에 터잡아 근로자를 해고할 수 있는 것"이라고 하거나(서울고판 2001.5.16, 2000누13121), 판매서비스직에 종사하는 근로자가 고객에 대한 불친절로 인해 2회 연속으로 인사고과

1) 이 글은 '능력중심 인력운영의 합리적 구축 방안에 관한 토론회'(주최: 연세대 미래융합연구원, 2015. 11.24)에서 발표한 내용을 수정·보완한 것임을 밝힙니다.

결과 최하위등급을 받은 것은 일반해고 사유에 해당하며 해당 근로자가 사용자의 정당한 인사발령에 불응하면서 장기간 업무를 거부한 것은 징계해고 사유에도 해당한다고 본 사례(서울고판 2013.4.25, 2012누34220)가 있음.

○ 학계에서는 일반해고를 근로자의 일신상의 사유와 근로자에게 귀책될 수 있는 행태상의 사유로 나누거나(김형배, '노동법'(제24판), 688면), 근로자의 사정에 따른 해고를 징계해고와 일반해고(통상해고)로 구분하고 징계와 무관한 해고를 일반해고(통상해고)라고 칭하고 있음(임종률, '노동법'(제13판), 522면).

○ 최근의 논의에서는 통상해고는 향후 계속고용 가능성의 관점과 근로자 보호 목적에서 사용자로 하여금 배치전환 등의 조치를 통해서도 계속고용의 장애사유를 제거할 수 없는 경우에만 해고를 인정하는 최후수단성이 함께 요청된다고 하는 견해,[2] 통상해고는 장래에도 근로자와의 근로관계를 계속 유지하는 것이 가능하지 않은 경우이며 징계해고는 과거에 잘못한 근로자의 행태에 대한 제재라고 파악하는 견해[3] 등이 있음.

○ 실무에서는 '근로자의 직무수행능력이 부족하거나 근무태도가 불량한 경우, 근무성적이 저조한 경우'(그 밖에도 '저성과', '업무부적응' 등 다양한 용어가 사용되고 있으나 이하에서는 판결문을 인용하는 경우를 제외하고는 '직무수행능력 부족'이라고 함)를 취업규칙 등에 대기발령의 사유로 규정하고 대기발령 후 일정 기간이 경과하였음에도 대기발령의 사유가 해소되지 않았음을 이유로 직권면직의 형식으로 근로자를 해고하는 사례와 직무수행능력 부족을 징계사유로 삼아 해고하는 경우가 많음.

○ 대기발령 후 직권면직이나 당연퇴직의 형식으로 해고가 행해진 경우에 대해 판례(대판 2007.5.31, 2007두1460 등)는 대기발령이 정당하여야 하며(대기발령의 업무상 필요성과 근로자의 생활상 불이익의 비교), 이 경우 직권면직이나 당연퇴직은 실질적으로 해고에 해당하므로 대기발령 당시에 이미 해고사유가 있었거나 대기발령 기간 중에 해고사유가 확정되어야 한다고 함(대기발령 기간 중에 사용자가 직무능력 향상을 위한 실질적인 조치를 취했는지와 근로자의 직무능력 부족이 개선되었는지에 대한 판단).

○ 징계해고로 다루어진 경우에 대해서 판례는 징계처분의 대상으로 수용하여 징계사유가 존재하는지와 징계절차를 지켰는지, 징계양정이 적정한지를 살펴 그 정당성 여부를 판단함. 하지만 직무수행능력 부족 자체를 기업질서 위반의 징계사유로 보기는 어려우므로 실무의 경향은 해고에 대한 법적인 이해와는 부합하지 않는 측면이 있음.

---

2) 박종희, '현행 해고보호제도의 체계적 이해와 해석에 관한 연구', 안암법학(제44호, 2014), 461면.
3) 권혁, '해고유형론 소고', 법학연구(제51권 제1호, 2010), 719면.

○ 직무수행능력 부족을 이유로 한 해고에 대해 체계적이고 통일적인 법리를 제시한 대법원 판례는 아직 없음. 다만, 판례는 정당성 여부가 다투어진 개별 사안을 통해 정당한 이유가 있는 해고라고 인정되려면 ①객관적인 자료에 따라 직무수행능력이 부족한지를 판단하여야 하고, ②인사고과는 합리적 기준에 따라 공정하게 평가하여야 하며, ③가능한 방법으로 직무능력 향상을 위한 개선의 기회를 부여하여야 함을 제시하고 있음.

○ 이하에서는 직무수행능력 부족을 이유로 한 해고의 정당성 여부가 다루어진 주요 판례를 위 3가지 항목에 따라 검토하여 관련 사례를 정리하고,[4] 이를 통해 관련 통상해고의 정당성 판단에 참고할 수 있는 시사점을 도출하고자 함.

2. 직무수행능력 부족에 대한 판단

(1) 일반적 기준

○ 직무수행능력이 부족한지를 어떻게 판단하며, 근로자의 직무수행능력이 어느 정도여야 부족하다고 할 수 있는가? 직무수행능력 부족을 정의하는 것이 쉽지 않음. 어떤 수준에 미치지 못할 때 직무수행능력이 부족하다고 평가할 수 있는데, 문제는 그 수준을 어떻게 정할 것인가임. 전문직과 같이 특수하고 개별적인 능력을 전제로 채용한 경우에는 담당할 직무와 역할을 고려해 상대적으로 쉽게 그 수준을 정할 수 있겠지만, 그렇지 않은 경우에는 평균적인 수준의 중등품질의 급부를 기준으로 할 것인지(객관설), 해당 근로자가 갖고 있는 능력을 발휘해야 하는 것인지(주관설) 등 어려움이 있음.[5]

○ 판례는 소송이 제기된 해당 사안별로 근로자의 직무수행능력이 부족한지를 개별적 · 구체적으로 판단하고 있으며, 대법원이 근로자의 직무수행능력 부족 여부를 판단하는 체계적이고 구체적인 기준을 직접 제시한 판례는 찾을 수 없지만, 대법원은 몇 사례를 통해 원심 법원이 언급하였던 직무수행능력 부족 여부의 판단 기준이나 방법을 그대로 인정한 바 있음.

---

4) 그러므로 앞으로 소개하는 판례의 사례는 판결문을 그대로 인용한 것이 아니라 해당 판례(하급심 포함)에 나타나 있는 사실관계와 법원의 판단을 요약하여 정리한 것임.

5) 이에 대한 보다 자세한 논의는 박종희, '저성과자에 대한 합리적인 인사관리방안과 관련한 법률상 쟁점 검토 - 전략적·체계적 관리방안의 수용가능성 검토를 중심으로 -', 고려법학(제75호, 2014), 337면 이하 ; 박지순, '지속적인 근무성적 및 근무태도 불량자 해고의 정당성 판단에 관한 연구', 17면 이하 참조.

○ 판례(대판 2002.7.26, 2000두9113)는 직무수행능력 부족이나 근무태도 불량은 사용자의 자의적 판단이 문제될 수 있음을 지적하면서, 사용자가 **객관적인 자료에 의해** 근로자의 직무수행능력 부족이나 근무태도 불량을 입증해야 함을 지적함. 해당 판례에서 '직무수행능력'이나 '근무태도' 자체가 근로자의 능력이나 태도에 대한 일반적이고 추상적인 평가를 전제로 하므로, 근로자의 직무수행능력이 부족한지는 **"인사고과 결과, 업무실적, 출결상황, 상급자나 동료 근로자의 해당 근로자에 대한 평가 등의 자료를 종합적으로 고려하여 판단"** 하여야 함을 제시함.

○ 판례(대판 2013.1.15, 2012두21369)는 단순히 인사고과에서 하위 일정 비율에 속한다는 이유로 한 해고는 그 정당성을 인정하기 어렵고 **"근무성적이 현저하게 나쁜 것이 증명되는 경우"** 에만 해고의 사유가 될 수 있다는 입장임. 같은 맥락에서 판례(대판 2007.2.9, 2006두18287)는 상대평가로 실시된 인사고과에서 최하위 등급을 받은 것만으로는 해당 근로자의 업무능력이 객관적으로 불량하다고 단정할 수 없음을 지적한 바 있음.

○ 요약하면 직무수행능력 부족이 **객관적으로** 존재하여야 하고 그것이 근로관계를 계속 유지할 수 없을 정도로 **중대하여야** 해고의 사유가 될 수 있다는 입장이며 (**객관성과 중대성**), 이는 아래와 같이 영업직 근로자의 경우에 대해서도 동일하게 적용될 수 있음.

○ 판례(대판 1991.3.27, 90다카25420)는 영업직 근로자에 대한 사안에서 업무실적이 다른 근로자에 비하여 상대적으로 낮은 정도가 아니라 **"근로자의 직위, 보수, 근무경력, 다른 근로자의 전반적인 근로성적 등 제반 사정을 참작하여, 일반적으로 기대되는 최소한의 실적에도 미치지 못하는 정도"** 에 해당해야 근로자로서 최소한도의 직무수행능력이 결여되었음이 인정된다고 함. 판례의 입장이 명확한 것은 아니나, 근로자가 맡고 있는 직위나 다른 근로자와 비교 등에 비추어 평균적인 수준의 중등품질의 급부를 기준으로 판단하는 이른바 객관설에 가까운 것으로 볼 수 있음.

(2) 관련 판례

가. 사무직 근로자의 직무수행능력 부족 인정 사례

□ **대판 2002.7.26, 2000두9113 ○○중앙회 사건 (대기발령 후 직권면직)**

직무수행능력이 부족하여 담당업무가 자주 변경된 점, 업무시간에 장시간 동안 사적인 전화를 하여 창구 고객의 불만을 초래한 점, 업무처리 불성실로 고객의 항의를 받은 점, 신병치료를 이유로 무단결근을 한 점, 업무가 남아있어도 퇴근

해버리거나 일과 중에 낮잠을 자는 등 불성실한 근무태도를 보인 점, 이로 인해 동료 직원들과 잦은 마찰을 빚었고 상급자들과 동료 직원들이 해당 근로자의 인사조치(교체)를 요구한 점, 노동조합 지부장조차 해당 근로자를 해고시켜야 한다는 의견을 제시한 점, 인사고과 결과 계속하여 최하위에 가까운 평정을 받아온 점 등의 사실을 들어 해당 근로자의 직무수행능력과 근무태도가 극히 불량하다고 인정

□ **대판 2007.3.15, 2006두17413 ○○조합 사건 (대기발령 후 면직)**

업무수행능력 미숙을 이유로 2회에 걸쳐 대기발령을 받은 전력이 있는 점, 해당 근로자가 업무를 다른 직원에게 전가하는 등 제대로 처리하지 아니하여 민원인이나 고객으로부터 이의제기를 받은 점, 동료직원들이 해당 근로자의 업무미숙을 이유로 불편을 겪고 있으므로 해당 근로자를 업무에서 배제하여 주기를 원하는 건의서를 제출한 점, 단순한 주화포장기 등의 업무조차 제대로 수행하지 못한 점, 사용자가 업무습득기간까지 부여하면서 업무수행능력 배양을 위한 조치를 취하였음에도 불구하고 별다른 진전이 없는 점에 비추어 직무수행능력이 부족하고 근무성적이 극히 불량하다고 인정

□ **대판 2012.5.9, 2012두4760 ○○자동차 사건 (징계해고)**

고객상담업무를 담당하면서 다른 근로자와 비교하여 업무실적이 현저히 부진하였고 인사고과에서도 3년 연속 최하위등급을 받은 점, 역량향상프로그램에 참가한 근로자들 중에서도 최하위에 해당하는 점, 회사의 허락없이 근무시간 중에 인터넷 게시판에 논평이나 칼럼을 게시하고 인터넷 블로그에 회사 비리 고발을 의도로 온라인 소설을 연재한 점 등을 근무성적 및 근무태도 불량의 징계해고 사유로 인정

□ **대판 2012.9.27, 2012두13955 ○○산업 사건 (징계해고)**

소극적인 업무태도로 인해 현장소장이 여러 차례 해당 근로자의 교체를 요청한 점, 업무를 다른 직원에게 전가하고 보고를 누락하는 등 업무를 태만히 한 점, 10년간 인사고과 결과가 대부분 하위 20% 이내이고 최근 2년간 인사고과 결과가 하위 10% 이내인 점 등을 들어 직무수행능력의 결여를 징계사유로 인정

□ **대판 2013.1.15, 2012두21369 ○○공단 사건 (보직대기 후 직권면직)**

다면평가로 실시된 인사고과 결과 부서장 94명 중 93위를 하여 보직대기되었고 보직대기 기간 중 실시된 재교육에서도 최하위를 기록한 점, 재교육 후 업무에 복귀시켜 기회를 부여했으나 업무태도가 개선되지 않은 점, 다음해 인사고과 결과 전 직원 1,026명 중 최하위인 점 등을 들어 직무수행능력이 부족하다고 인정

□ **대판 2014.11.13, 2014두10622 ○○자동차 사건 (징계해고)**

최근 3년 연속 인사고과 결과 하위 2% 이내인 최하위권에 해당한 점, 상급자가 작성한 '성과역량관리 상시기록표'에 주간업무계획 미작성 등 근무태만의 사례들이 일자별로 기재되어 있고, '행동관찰일지'를 통해 보고서 미수정 등 업무지시 불이행의 사례들이 다수 확인되는 점 등을 이유로 근무성적 불량, 근무태만, 지시불이행 등의 징계사유에 해당함을 인정

□ **대판 2015.3.12, 2014두15221 ○○진흥원 사건 (대기발령 후 직권면직)**

불법하도급 알선과 상급자에 대한 욕설 등으로 정직 6월을 받은 전력이 있는 점, 취업규칙에 인사고과 결과 3회 연속 최하위등급을 받으면 대기발령 사유에 해당하는데 해당 근로자가 최근 5회 연속으로 최하위등급을 받은 점 등으로 볼 때 근무성적이 불량하다고 인정

□ **서울고판 2003.9.26, 2003누3316 ○○회사 사건 (징계해고)**

비교적 단순하고 정형적인 인사보조업무를 담당하였음에도 동일한 유형의 업무상 실수를 반복한 것이 상급자가 그 사례를 기록한 자료를 통해 확인되는 점, 매년 인사고과에서 업무수행능력과 지식을 향상시키라는 지시(주의, 경고)를 받았으나 개선이 되지 않은 점, 인사고과 결과가 지속적으로 저하된 점을 징계사유로 인정

□ **서울행판 2009.4.17, 2008구합34443 ○○센터 사건 (대기발령 후 직권면직)**

대기발령 이전에 2차례 징계(직무태만·회사발전 저해・언어폭력을 사유로 견책, 보조금 부적정 집행에 대한 지도 감독 소홀을 사유로 경고)를 받았던 점, 노동조합으로부터 근무능력에 대한 검증 요구를 받았으나 해당 근로자가 검증을 거부하여 팀장에서 팀원으로 직위가 강등된 점, 인사고과 성적이 2년 연속 매우 낮았고(2005년 전체 69명중 65위(하위 5.8%), 팀장 6명중 5위, 3급이상 13명중 12위, 2006년 각 67명중 66위, 5명중 5위, 12명중 12위), 인사고과는 다면평가 방식으로 이루어져 객관성이 상당히 인정되는 점 등을 이유로 직무수행능력에 심각한 문제가 있다고 판단

나. 영업직 근로자의 직무수행능력 부족 인정 사례

□ **대판 1987.4.14, 86다카1875 ○○신문 사건 (대기발령 후 해임)**

판매관리부 차장인 근로자가 1년 동안 미수금 회수 실적이 전혀 없거나, 같은 업무에 종사하는 다른 근로자의 실적(4,150만여원)에 현저히 미치지 못하는 실적(330만원)을 보인 것은 성실히 복무할 책임을 다하지 않은 잘못이라고 인정

□ **대판 1991.3.27, 90다카25420 ○○보험 사건 (대기발령 후 해임)**

보험업을 영위하는 회사가 거수실적(보험계약을 체결하여 보험료를 입금시킨 실

적)에 따라 회사운영의 성패가 좌우된다고 할 수 있는 점, 영업부장이었던 근로자가 11개 영업부서 중에서 최하위의 실적을 기록하여 영업개발부 관리역으로 발령받았던 점, 관리역으로서도 거수실적이 저조하여 총무부 대기발령을 받았던 점, 다시 관리역으로 발령받았으나 목표금액 대비 평균 22.1% 정도의 실적에 불과하였고 이는 해당 근로자(부장)보다 하위급인 과장급 직원들의 평균 실적의 6% 정도 밖에 되지 아니한 점을 거수실적 불량의 징계사유로 인정

□ **서울행판 2000.12.15, 2000구21853 ○○일보 사건 (대기발령 후 당연퇴직)**

지방신문사인 회사의 경영실적이 매우 열악하였고 광고 수주와 수금실적이 사업운영에 절대적인 요소인 점, 광고영업직원의 실적이 입사 후 1년도 경과하기 전부터 다른 영업직 사원들에 비하여 현저히 부진하였고 연간 실적이 동료 직원들의 1/4분기 실적에도 미치지 못한 점, 광고주로부터 채권확보를 위한 어음조차 교부받지 않는 등 광고료 회수 노력을 태만히 한 점은 직무수행능력의 부족 또는 근무태도 불성실에 해당한다고 인정

□ **서울고판 2013.4.25, 2012누34220 ○○쇼핑 사건 (징계해고)**

판매서비스직인 마트 계산원으로 근무하던 근로자가 계산능력 부족, 고객응대 불친절 등의 이유로 2010년 하반기 근무평가에서 하위고과를 받아 경고를 받았음에도 회사의 인사발령에 불응하면서 업무조차 거부하여 2011년 상반기 근무평가에서 하위고과를 받아 연속하여 하위고과 2회를 받은 것은 회사 취업규칙에서 정한 일반해고 사유인 '연속 하위고과 2회 이상을 받는 등 근무성적 또는 능률이 현저하게 불량하다고 인정되는 경우'에 해당하며, 해당 근로자가 전보발령에 장기간 불응하면서 업무를 거부한 것은 취업규칙에서 정한 징계해고 사유에도 해당한다고 판단

다. 사무직 근로자의 직무수행능력 부족 불인정 사례

□ **대판 2005.11.25, 2005두9217 ○○위원회 사건 (대기발령 후 직권면직)**

상급자의 업무 지시에 대해 다른 직원들은 모두 이를 차질 없이 수행하면서 야간근무명령까지도 이행하였음에도 해당 근로자는 자신에 대한 업무지시를 파악하지 못한 채 기한 내에 충실히 과제를 수행해내지 못하였고 야간근무명령마저 무시하는 등 직무수행능력이 현저히 부족하다는 것이 사용자의 주장이나, 5년 이상 근무하면서 그 이전에 한 번도 근무수행능력이나 근무태도와 관련해서 경고·시말서·징계 등을 받은 사실이 없어 업무지시를 이행하지 않았다고 인정하기 부족하고 인정할 증거도 없는 점, 2002년도 인사고과 결과가 26명중 26위이나 1997년 11월 입사후 2001년도까지 근무평가 결과 별다른 문제점이 없는 평가를 받아 계약이 갱신 체결되었던 사실로 볼 때, 단기간(1년) 동안의 근무평정 결

과가 최하위라는 점만으로 근로자가 일할 수 없을 만큼 직무수행능력이 현저히 부족하다고 단정할 수 없다고 판단

□ 대판 2007.2.9, 2006두18287 ○○건축사무소 사건 (징계해고)

인사고과가 상대평가 방식이므로 최하위 등급을 받은 것만으로 업무능력이 객관적으로 불량하다고 단정할 수 없는 점, 감리업무 특성상 시공사와의 의견충돌이나 업무상 마찰이 발생할 수밖에 없는데 이를 해결하는 과정에서 해당 근로자의 독선적이고 비협조적인 성격으로 인해 업무처리가 원만하게 이루어지지 않은 경우가 있으나 업무미숙·근무태만·비위행위 때문이 아닌 점, 회사에서도 근로자의 기술적인 업무능력과 전문성 등은 인정되나 근로자의 대인관계상의 문제로 잦은 업무상 마찰이 발생한 것으로 파악하고 있었던 점, 2003년 상반기 이후 특별한 업무를 부여하지 않아 사실상 업무능력을 판단할 수 없었던 점 등에 비추어 인사고과 결과 4회 연속 최하위 등급을 받은 것만으로는 근무성적이 해고할 정도로 객관적으로 불량한 정도라고 할 수 없다고 판단

□ 대판 2007.3.15, 2007두1477 ○○연맹 사건 (대기발령 후 당연면직)

이사회에 각서 미제출, 절차를 무시한 급·호봉 정정 및 미지급분 추가지급 요청, 저조한 근무평정점수를 사유로 인사규정의 '직무수행능력 또는 성실성의 현저한 부족으로 근무성적이 아주 불량하다고 인정되는 자'에 해당된다는 이유로 대기발령을 하였으나, 첫째, 각서를 제출하지 않은 다른 직원들은 신분상 불이익을 받지 않은 점에 비추어 볼 때 이러한 사유를 해당 근로자의 직무수행능력 또는 성실성이 현저히 부족하다고 할 수 없는 점(각서 제출 관련 경위를 보면 사무국의 재정이 부족하여 부장인 해당 근로자를 포함하여 같이 근무하는 3명이 협의하여 그 중 1명을 퇴직하도록 지시한 사무국장에게 퇴직 대신 급여 50% 지급보류를 제시하자, 사무국장이 지급보류가 아닌 반납으로 수정하면서 자신도 동참하겠다고 하였는데 실제 급여지급일이 되자 자신은 급여 반납에 참여할 수 없다고 하였고, 이에 실망한 직원들이 연명으로 사무국장의 금품수수 비리를 탄원하자 연맹이 사무국장에게 동 금품수수금액의 변상하도록 하면서 직원들에게는 향후 화합하여 근무하겠다는 각서를 제출하도록 하였음), 둘째, 해당 근로자가 사무국장의 결재 없이 연맹에 급여체계에 대한 조정을 요청하기는 하였으나 그 이전에 이미 사무국장에게 급여체계에 대한 조정을 해달라고 요청하였음에도 답변이 없자 직접 연맹에 제출한 것이므로 직무수행능력 또는 성실성이 현저히 부족하다고 할 수 없는 점, 셋째, 사무국장이 객관적 자료 없이 근무평정에서 해당 근로자에게 낮은 점수를 부여하였고 근무평정 시기를 지키지 않은 점, 이전에 저조한 근무평정을 사유로 대기발령이나 징계를 한 전례가 없는 점에 비추어 볼 때, 대기발령의 사유가 인정되지 않는다고 판단

□ 서울고판 2005.6.30, 2004누17954 ○○교통 사건 (징계해고)

시내버스 회차지에서 운행일보를 기록하는 근로자가 일부를 누락하거나 허위로 기재한 사실이 있으나, 05시부터 24시까지 19시간 동안 혼자 근무하면서 하루 평균 551회 정도의 버스운행 내역을 기재하는데 버스 운행간격이 평균 2분 정도에 불과하여 식사를 하거나 화장실을 갈 때에는 그 기재 자체가 불가능한 실정이므로 회사가 어느 정도의 기재 누락을 묵인해 온 점, 근로자가 음주운전으로 경찰 조사를 받아 출근하지 못하게 되자 신속히 회사에 연락을 하여 대직자가 근무할 수 있도록 조치를 취한 점 등을 볼 때, 취업규칙의 해고사유인 '근무성적이 극히 불량한 자'에 해당하지 않는다고 판단

□ 서울행판 2014.10.16, 2013구합22338 ○○회사 사건 (대기발령 후 직권면직)

2005년~2012년까지의 인사고과가 하위권인 C~D로 평가되고 철도관련 지원 업무나 단순하역 업무를 수행하였으며 물류관련 전산업무능력도 어느정도 부족하다고 인정되기는 하지만, 2005년 회사로 전적(채용)되는 과정에서 업무능력도 일정부분 인정받은 것으로 보이는 점, 업무에 필요한 전산능력은 일반인이라면 할 수 있는 기초적인 내용인데 해당 근로자가 업무를 수행하지 못할 정도로 전산능력이 현저히 부족하다는 입증이 불충분하다고 판단

라. 영업직 근로자의 직무수행능력 부족 불인정 사례

□ 대판 2009.9.24, 2009두12600 ○○증권 사건 (대기발령 후 징계면직)

회사에 의해 명예퇴직 대상자로 선정되었으나 사직서 제출을 거부하자 경영구조개선 및 기구개편을 이유로 대기발령을 받았는데 대기발령 기간 동안 아무런 직무도 부여하지 않은 점, 대기발령 기간 동안 단지 4차례에 걸쳐 생존능력강화교육만을 실시하였는데 교육과정이 실질적으로 근무성적이나 직무수행능력을 평가하기에 적합하지 않은 점, 위 교육 종료 후에도 아무런 업무도 부여하지 않고 징계면직할 때까지 3개월 동안 계속하여 대기상태를 지속한 점 등을 이유로 근무성적이 극히 불량하거나 직무수행능력이 부족하다 할 수 없다고 판단

□ 대판 2014.2.27, 2013두24273 ○○회사 사건 (해고)

선물거래로 발생한 1,800만원의 투자손실에 대해 근로자는 손실 부분이 대표이사의 지시에 따라 거래하거나 대표이사가 임의로 투자한 부분에서 발생한 것이고 본인이 자기책임으로 투자한 부분에서는 이익이 발생하였다고 주장함에도 회사 입증이 불충분하므로 근로자의 업무능력 부족으로 인한 것이라고 단정하기 어려운 점, 회사는 근로자가 비철금속 분야에서 선물거래 경험이 없다는 사실을

잘 알면서 채용하였던 점, 대표이사가 임의로 선물거래를 하거나 대표이사의 지시로 선물거래가 이루어지기도 한 사실이 인정되므로 업무능력이 부족하다고 볼 수 없다고 판단

□ 대전지판 2015.1.8, 2014구합101339 ○○회사 사건 (징계해고)

근무성과가 다른 직원에 비해 저조한 것은 사실이나 해당 근로자가 처음으로 법무관리시스템 솔루션 판매를 담당하게 되었고, 업무평가 기간이 1년(2회 평가)에 불과한 점, 회사의 사정에 따라 채용시 예정했던 업무와 다른 업무를 부여하였고 그 업무도 회사의 기존 영업업무가 아니라 새로이 판매권을 인수한 분야인 점, 상급자로부터 3차례나 사직을 권고받아 업무에 집중하기 어려웠을 것으로 보이는 점 등을 이유로 영업실적 저조가 징계사유로는 인정되나 해고될 정도로 업무능력이 현저히 저조하거나 거듭 반복하여 근무성적이 불량하다고 보기는 어렵다고 판단

□ 서울행판 2004.9.17, 2003구합23769 ○○증권 사건 (대기발령 후 징계해고)

회사가 책상·컴퓨터·전화 등 영업을 위한 사무기기 및 영업관련 자료를 제대로 지원하지 않은 점, 회사가 영업실적 기준을 정함에 있어 상담역의 경우 기존 고객 확장 유치시 법인의 경우는 불인정, 개인인 경우 50%만 인정하는 등 일반 영업직에게 인정되는 실적을 인정하지 않아 해당 근로자의 영업실적을 제외시킨 점, 벤처회사로부터 20억원의 투자를 성사시켰으나 투자기준에 맞지 않는 등 매우 엄격하고 높은 목표가치를 부여함으로써 사실상 영업실적을 제대로 달성할 수 있는 여건을 조성해 주지 않은 점, 대기발령 이후 근로자는 영업현장으로부터 차단되어 있었고 사용자는 7개월간 근로자에게 아무런 연락을 취하지 아니한 채 있다가 징계해고 한 점을 들어 근로자에 대한 상담역 전보 전후 및 대기발령 당시 근로자의 근무성적이 근로자의 지위와 보수에 비추어 일반적으로 기대되는 실적에 미치지 못할 정도로 부진하였다고 볼 수 없다고 판단

(3) 요약 및 검토

○ 판례는 원칙적으로 인사고과 결과만을 갖고서 바로 근로자의 직무수행능력이 부족한지를 판단할 수 없다는 입장임을 확인할 수 있음. 근로자가 인사고과 결과 하위등급을 받았거나 하위자에 해당한다면 다른 근로자들과 비교하여 상대적으로 직무수행능력이 부족하다고 볼 여지는 있음. 하지만 인사고과가 상대평가 방식이 아닌 절대평가 방식으로 이루어졌다고 하더라도 인사고과 등급이 근로자의 직무수행능력을 설명하거나, 하위등급을 받은 인사고과 결과가 바로 근로계약관계를 계속 유지할 수 없을 정도로 해당 근로자의 직무수행능력이 현저히 부족하다는 점을 증명하는 것은 아니므로 판례의 견해가 타당하다고 생각됨.

○ 인사고과에서 연속 최하위등급을 받은 사실을 일반해고사유로 인정한 하급심 판례(서울고판 2012구합17414)가 있기는 하지만, 직무수행능력을 판단할 때 인사고과 결과가 중요한 고려요소라 하더라도 인사고과 결과 그 자체만으로는 근로자의 직무수행능력이 어느 정도 어떻게 부족한지 그로 인해 업무수행에 어떠한 차질이 있었는지를 충분히 설명할 수 없는 경우가 많을 것임. 따라서 사용자는 근로자가 그와 같은 저조한 인사고과 결과를 받게 된 구체적인 원인이나 이유로서 근로자의 평소 업무실적, 출결상태(결근, 지각, 조퇴, 외출 등 근태), 상사나 동료 등 다른 근로자의 평가, 그 밖에 확인가능한 자료를 통해 해당 근로자의 직무수행능력이 부족함을 객관적으로 입증하여야 할 책임을 부담하는 것임.

○ 직무수행능력이 영업 · 판매 · 수금 실적과 같이 수치로 계량화될 수 있는 직종에 종사하는 근로자의 경우, 최소한도로 갖추어야 할 직무수행능력을 판단할 수 있는 기준으로서 '근로자의 직위나 보수 등에 비추어 일반적으로 기대되는 최소한의 실적'이 어느 정도이고 이를 어떻게 산정할 것인지를 판례가 구체적으로 제시하고 있지는 않음.

○ 다만, 판례는 영업실적 등이 해고의 이유가 된 사안에서 근로자가 받고 있는 임금액, 근무경력, 다른 근로자의 실적과의 대비 등을 통하여 직무수행능력의 부족 여부를 개별적으로 판단하고 있음. 예컨대 신문사 영업직원의 실적이 다른 근로자의 1/10도 되지 않은 경우, 보험회사 영업직원의 실적이 하위직급자 평균의 6% 정도에 불과한 경우, 광고영업직원의 실적이 다른 근로자의 1/4에도 미치지 못하고 광고료 회수를 위한 조치도 하지 않은 경우에 대해 해고사유로 인정하였다. 해고가 정당한가의 여부는 개별적 사례에 따라 구체적으로 판단되어야 하며, 근로자가 직장을 상실함으로써 받게 되는 손해와 근로관계를 종료시킴으로써 얻게 되는 사용자의 이익 사이의 신중하고 포괄적인 이해형량이 이루어져야 함(헌재 2005.3.31, 2003헌바12 참조)을 감안할 때 판례의 위와 같은 판단방식은 불가피하다고 볼 수 있음.

○ 해고의 정당한 이유가 있는지는 개별적 사안에 따라 구체적으로 결정될 일이지만 그 일반적 내용은 근로관계를 계속 유지할 수 없을 정도의 이유 즉 해당 근로자와의 근로관계의 유지를 사용자에게 더 이상 기대할 수 없을 정도의 것(계속고용의 기대가능성이 없는 경우)이어야 하고(대판 1987.4.14, 86다카1875 등 참조), 직무수행능력의 부족을 해고의 사유로 인정하더라도 계속적 채권관계인 근로계약의 존립보호 필요와 해고의 최후수단성 원칙이 간과되어서는 아니되므로, 근로자의 직무수행능력이 현저하게 부족하여야 하며 직무수행능력 부족이 일시적이어서 기회를 부여하면 개선될 수 있을 때에는 정당한 해고 사유로 인정될 수 없음.

○ 사용자의 불합리한 업무배치로 근로자가 직무수행능력을 발휘하지 못한 때, 사용자측의 사정에 의한 것일 때, 근로자에게 직무수행능력 부족의 책임을 묻기 어려운 사유가 있을 때 등에는 직무수행능력이 부족하다고 판단할 수 없음. 따라서 판례는 사용자가 근로자를 채용할 당시 해당 근로자의 경력이나 근무분야, 업무경험에 대해 알고 있었으면서도 채용 후 다른 분야의 업무를 부여하고 얼마 지나지 않아 업무능력이 부족하다고 판단한 것은 부당하며(대판 2014.2.27, 2013두24273), 사용자가 경력직으로 신규채용한 근로자에게 새로운 분야의 영업업무를 부여하고 단지 1년간 영업실적이 없다는 이유로 해고될 정도로 해당 근로자의 업무능력이 저조하거나 근무성적이 불량하다고 해고한 것은 정당하지 않다(대전지판 2015.1.8, 2014구합101339)고 봄.

3. 인사고과의 합리성과 공정성

(1) 일반적 기준

○ 근로자의 직무수행능력을 판단할 때 인사고과 결과가 중요한 고려요소가 되는데, 판례(대판 2012.8.17, 2012두10116)는 "인사고과는 해당 근로자를 상대로 한 전인격적, 복합적인 평가로서 인사권자인 사용자의 고유권한이라고 할 것인바, 모든 평가요소를 객관화하기 곤란하여 원칙적으로 그 평정을 위한 평가기준이나 항목의 설정, 점수의 배분 등에 있어 사용자에게 광범위한 재량이 인정된다. (중략) 인사고과제도의 목적과 성질 등에 비추어 사용자는 근로자의 **근무실적이나 업무능력 등을 중심으로 객관적이고 공정한 평정이 이루어지도록 노력하여야 하고 그것이 불순한 동기로 남용되어서는 아니된다**" 고 함.

○ 근로자의 역량과 업무능력, 태도를 평가하여 직원을 적재적소에 배치하고 그에 상응하는 보상·승진 등을 시행하기 위하여 필요한 요소들을 인사고과의 평가요소로 삼고 있는지, 인사고과 결과의 공정성과 객관성을 담보하기 위하여 합리적인 평가원칙을 세우고 있는지 등이 중요하게 고려되어야 함(대판 2014.11.13., 2014두10622).

○ 사용자의 인사고과가 불합리한 기준이거나, 특정 근로자 개인이나 집단에게 자의적이고 불공정하게 실시한 인사고과 결과라면 이를 근거로 근로자가 직무수행능력이 부족하다고 할 수 없음(대판 2015.6.24., 2013다22195).

○ 즉 인사고과는 사용자의 재량권에 속하기는 하지만, **합리성**과 **공정성**을 갖추어

야 함. 근로자의 직무수행능력이나 업무실적을 제대로 반영할 수 있는 평가 내용과 절차를 갖추고 있어야 하며(합리적 기준), 평가자의 주관적 판단을 최소화하고 정해진 고과기준에 따라 공정하게 심사하여야 함(공정한 평가).

(2) 관련 판례

가. 합리적 기준 관련 사례

□ 대판 2012.5.9, 2012두4760 (징계해고)

근로자에 대한 인사평가는 사용자의 권한에 속하는 것으로서 사용자에게는 그 인사평가의 방법 등을 결정하는 데에 상당한 재량을 가지고 있고, 인사평가의 본질상 정성적인 요소가 포함되어 있더라도 쉽사리 자의적이라거나 권한을 남용한 것이라고 단정할 수 없음. 사용자가 2006년부터 2008년까지 행한 인사평가나 역량향상프로그램 대상자의 선정 이후 이루어진 행동관찰 및 검증위원회의 검증의 기준과 방식, 그리고 실제 운용이 사용자의 인사재량권의 범위를 벗어나 공정성이나 객관성을 결여하였다고 보이지 아니함.

□ 대판 2012.7.12, 2012다31949 (계약갱신 거절)

근로의 양과 질에 대한 평가에는 수치로 계량되는 객관적인 실적뿐만 아니라 기업조직에의 융화 정도 등 수치로 계량할 수 없는 부분에 대한 주관적인 평가도 포함되는 것이므로, 일부 평가 항목에 관하여 객관적인 판단 기준이 마련되어 있지 않아 상급자의 주관적인 평가에 좌우될 우려가 있다는 사정만으로 근무평정기준이 부당하다고 보기 어려움.

□ 대판 2007.2.9, 2006두18287 (징계해고)

회사의 인사고과제도는 절대평가방식이 아닌 상대평가방식이므로 단지 인사고과에서 최하위등급을 받았다는 것만으로 근로자의 근무성적이 사회통념상 고용관계를 유지할 수 없을 정도로 객관적으로 불량한 정도에 이르렀다고 보이지는 않으므로 회사가 이를 이유로 근로자를 징계면직한 것은 사용자의 인사권을 남용한 것임.

□ 대판 2006.2.24, 2002다62432 (시용근로자 해고)

평가대상자의 근무태도, 업무능력 등을 평가함에 있어 통상의 평균적인 직원의 그것을 기준으로 하여 이와 비교하여 평가하는 것은 가능함(원심 고등법원 판결에서 근로계약의 해지가 정당하지 않은 이유로서 시용조건부 근로계약 해지의 성격상 당해 근로자의 업무적격성 등을 절대적으로 평가하여야 함에도 상당수의 평정자가 다른 직원들과의 비교를 통하여 평가한 것을 상대적인 평가로 보고 이 점을 열거한 점은 부적절하다고 지적함).

□ 대판 2005.10.28, 2005두9729 (징계해고)

평가등급은 S, A, B, C의 4등급으로 되어 있으며, S, A, B 등급의 경우 일정비율이 주어지지만 C등급은 강제분포가 아닌 임의분포로서 1998년과 1999년의 경우 1,200여 명의 사원 중 C등급을 받은 사원은 각 3명, 2000년 상반기에는 단 한 명도 없었고, 2001년 상반기에 3명, 하반기에 1명에 불과할 정도로 C등급이 부여되는 경우는 거의 없을 정도여서, 인사고과자가 피고과자에게 C등급을 줄 경우 피고과자의 능력이나 업무수행 내용 및 자세 등이 더 이상 어떠한 업무도 수행하기 어려운 상태에 있다는 의미로 받아들여지고 있음. 근로자의 그 동안의 근무태도와 전력, 사용자의 인사고과 방법과 근로자가 2회 연속 최하위 등급인 C를 받은 경위 등 제반 사정을 종합하여 보면, 근로자에 대한 징계로 해고를 선택하였다고 하더라도 그 징계 양정이 과중하여 징계권을 남용하였거나 일탈한 것이라고 볼 수 없음.

□ 서울행판 2004.9.17, 2003구합23769 (대기발령 후 징계해고)

회사 관리지침에 따랐다는 당시 근로자의 개인종합평가 총 평점 75점의 평가비중이 다면평가 40%, 인사평점 40%, 고객관리 19%로서 그 배점비율의 근거가 없을 뿐 아니라, 회사 직원들의 기준연봉 결정을 위한 개인업적평가 기준의 평가비율인 다면평가 20%, 인사평점(부서장평가) 30%, 고객관리(개인별 영업실적) 50%와는 다른데다가 다면평가의 비중이 고객관리(영업실적)의 비중보다 훨씬 높아 영업직인 근로자에 대한 평가기준으로서 불합리함.

나. 공정한 평가 관련 사례

□ 대판 2015.6.24, 2013다22195 (임금 삭감)

사용자가 부진인력 관리계획을 수립한 후 부진인력 대상자에게 인사고과, 업무분담 등에서 불이익을 주는 차별정책을 시행하였고, 합리적인 이유 없이 부당한 인사고과를 하였으므로 재량권을 남용한 것으로서 위법함.

□ 대판 2015.1.15, 2012두18868 (계약갱신 거절)

사용자가 마련한 정규직 전환을 위한 기준상으로는 기간제 근로자인 부서원의 정규직 전환에 관한 근무평가는 부서장, 담당임원, 대표이사로 이어지는 3단계 평가절차를 거치게 되어 있는데, 근로자들에 대한 부서장 평가 의견이 만 2년 근무자에게는 부적절한 '계약직 유지' 임에도 담당임원은 의견란에 아무런 기재나 표시를 하지 않은 채 서명만 하였으므로, 근로자들에 대한 담당임원의 평가가 없었다고 보아야 하고, 여러 사정에 비추어 볼 때 근로자들에 대한 담당임원의 의견제시가 매우 중요한 상황이었는데도 그것이 없었던 평가절차 상의 잘

못은 중대하다고 할 수 있으며, 부서장이 법률전문가나 인사전문가가 아닌 등의 이유로 그 평가가 합리적이고 공정하였는지 의구심이 들 뿐만 아니라, 계약직 유지' 라는 평가 결과의견이 반드시 정규직 전환 대상이 아니라는 취지라고 해석할 수도 없고, 이와 달리 보게 되면 사용자는 평가 결과의견을 자신 마음대로 해석할 수 있게 되어 정규직 전환 기준과 절차는 객관성과 공정성을 상실하게 됨.

□ 대판 2007.3.15, 2007두1477 (대기발령 후 당연면직)

근무평정의 평정요소와 배점이 근무실적 16점(직무의 양, 직무의 질 각 8점), 근무수행능력 12점(지식 및 기술, 이해 및 판단력, 창의성, 관리 및 통솔력 각 3점), 근무수행태도 12점(책임감, 적극성, 협조성, 성실성 및 규율 준수 각 3점)으로 구성되어 있는데, 근무수행태도 관련 항목인 책임감, 적극성, 협조성, 성실성 부분은 그 평정의 객관성 유지가 쉽지 않은 부분이므로 가능한 한 그 판단을 위한 객관적 기초자료를 마련하고 그를 토대로 평정을 하여야함에도 사무국장이 별다른 자료 없이 해당 근로자에게 낮은 점수를 부여한 점, 인사규정상 근무평정은 연 2회, 3월 말과 9월 말을 기준으로 실시하여야 한다고 규정되어 있음에도 사무국장이 해당 근로자의 탄원서 등의 제출로 인하여 관계가 악화된 상황하에서 2003년도 근무평정을 2004.1.1 작성한 점 등에 비추어 볼 때, 근무성적 불량이라는 대기발령 사유가 인정되지 않음.

(3) 요약 및 검토

○ 근로자의 직무수행능력이 계량화된 수치로 나타나지 않는 경우에는 비계량적·주관적 평가기준의 활용이 불가피한데 판례는 비계량적·주관적 평가기준이라고 하여 그 자체만으로 바로 추상적·자의적인 불합리한 평가기준이라고 보지 않으며, 평가 항목의 내용과 구성, 다면평가 등 평가단계의 다양화, 외부의 중립적인 평가자 선정 등 다른 요소들을 종합적으로 감안하여 합리적인 기준인지를 판단함. 평가항목을 세분화 한 경우, 다면평가로 객관성을 높인 경우, 평가위원회 등 복수평가자를 두거나 여러 평가단계를 갖춘 경우 등에는 합리적 평가기준으로 인정될 가능성이 더 높을 것임. 그 밖에도 판례는 합리적 인사평가 기준인지를 판단할 때 평가대상 근로자에게 평가결과를 공개하고 의견을 청취하고 있는지, 이의제기 절차가 마련되어 있는지 여부 등을 감안하고 있음.

○ 업무의 성격이나 활용 목적 등에 따라 평가대상 근로자가 갖고 있는 능력이나 성과에 따라 개별적으로 평가하는 절대평가 기준과, 평가대상 근로자들을 서로 비교하여 순위를 매기는 방식의 상대평가 기준을 선택하여 활용할 수 있음. 하지만 최하위 등급에 의무적으로 일정 인원을 할당하도록 하는 등 상대평가 기준인 경우 최하위 등급을 받은 사실만으로 바로 업무 능력이나 성과가 현저히 부

족하다고 판단할 수 없음. 이때에는 근로자의 업무수행 중에 직무수행능력 부족으로 인해 발생한 구체적 행위와 근무태도, 그로 인한 업무지장 등 최하위 등급을 받은 이유와 근거가 제시되어야 함.

○ 이에 비하여 상위등급은 상대평가를 하지만 최하위 평가등급에 대해서는 인원비율이 할당되어 있지 않은 임의분포로서 절대평가인 경우에는 상대평가 방식의 문제점을 어느정도 해소할 수 있고, 이는 최하위 등급을 연속해서 받은 근로자의 직무수행능력을 판단할 때 고려요소가 될 수 있음

○ 인사고과규정 등에 정해진 기준과 절차를 준수하여야 하고 이를 위반한 인사고과는 정당성이 인정되지 않으며, 특정 근로자에게 편파적인 평가가 행해져서 불이익을 주는 경우에는 공정한 인사고과로 볼 수 없음. 특히 인사고과가 해고에 관한 법적 규제를 회피하고 특정 근로자 개인이나 집단의 퇴출을 종용할 목적으로 하는 등 불순한 동기로 남용된 경우에는 위법부당함.

4. 개선 기회 부여

(1) 일반적 기준

○ 판례는 직무수행능력 부족이 인사고과 결과나 그 밖의 자료에 의해 확인되는 경우라도 곧바로 해고할 수 있는 것은 아니며, **재교육이나 직무재배치 등 가능한 방법을 통해 개선의 기회를 충분히 부여했음에도 개선되지 않은 경우**에 해고의 정당성이 인정된다고 함(대판 2013.1.15, 2012두21369 등).

○ 직무수행능력이 부족하다고 평가된 근로자를 대상으로 대기발령을 하면서 재교육(역량강화프로그램), 재배치 등을 실시한 진정한 목적이 **근로의지를 고취시키고 직무수행능력을 개선 향상**시키는데 있어야 하며(대판 2014.11.13, 2014두10622), **단지 해고를 위한 명분을 쌓으려는 것이어서는 아니된다**고 봄(대판 2015.3.12., 2014두15221).

(2) 관련 판례

가. 개선 기회 부여 인정 사례

□ **대판 2015.3.12, 2014두15221 (대기발령 후 직권면직)**

최근 5회 연속 최하위등급을 받아 대기발령된 근로자가 재교육 프로그램 기간 3개월 동안 14일이나 휴가를 신청하고 근무지를 이탈하기도 하는 등 재교육 대상

자로서 적절하지 못한 행동을 한 점, 제출한 과제(성과개선계획서)에 대한 인사담당부서의 보완요청을 거부하고 협의된 과제의 주제를 임의로 변경해 제출한 점, 상급자에 대한 불손한 언행 등으로 정직의 징계를 받은 전력이 있음에도 대기발령 기간중 인사부서 직원을 상대로 상급자를 비하하는 언행을 한 점을 들어 정당한 해고 이유가 있다고 인정

□ 대판 2014.11.13, 2014두10622 (징계해고)

역량강화교육이 업무수행실적이 저조한 직원을 대상으로 체계적인 교육을 통해 근로의지를 고취시키고 직무수행능력을 개선 향상시키는데 목적이 있었다면 역량강화교육을 받았음에도 업무부적격자로 인정된 일부 근로자를 해고(징계)할 것을 예정하였다고 하여도 이를 해고를 위한 수단에 불과한 것으로 평가할 수 없음. 해당 근로자가 1차 교육 결과 업무적격자로 선발되지 못해 2차 교육 대상자로 선정되었으면 교육에 적극 참여하고 더욱 열심히 근무하려는 자세를 가져야 함에도 불구하고 오히려 교육대상자들이 2차 교육을 거부하도록 주도하는 행위를 한 것 등은 징계해고 사유에 해당

□ 대판 2013.1.15, 2012두21369 (대기발령 후 직권면직)

인사고과 결과 보직대기된 근로자가 역량강화 교육(1차 재교육) 결과에서 6명중 6위를 한 점, 교육 후 현업에 복귀토록 하여 교통사고예방팀 업무를 부여하였는데 성과측정을 위한 설문조사 결과에서도 6명 중 최하위를 한 점, 다음해 인사고과 결과에서도 전체 직원 중 최하위를 기록한 점, 2차 재교육에서는 기준점수(60점)에 미달하여 교육을 수료하지 못한 점 등을 이유로 직무수행능력이 개선되지 않아 정당한 해고사유가 있다고 판단함

□ 대판 2012.9.27, 2012두13955 (징계해고)

사용자가 성과향상프로그램을 도입하면서 대상자 선정방법·선정절차·프로그램 내용·평가방법 등 전반에 대해 노사협의회에서 의결하는 절차를 거쳤으며, 그 목적이 직원 퇴출이 아니라 직무능력 향상과 직무재배치 기회 부여를 위한 것으로 보이고, 운영에 있어서도 개인별 맞춤형 교육 · 단계별 진행(통과시 교육 종료) · 임원 면담(지적, 독려, 개선기회 부여) 등으로 구성되었으며, 성과향상프로그램을 통과한 직원들의 다음해 인사평가 결과가 상당부분 개선되었다면, 성과향상프로그램의 운영과 평가가 적정한 것으로 인정됨. 해당 근로자는 성과향상프로그램 1, 2, 3단계 모두에서 50점 이하의 낮은 점수(6명중 5위, 6위)를 받아 직무수행능력이 개선되지 않음

□ 대판 2012.5.9, 2012두4760 (징계해고)

최근 3년 연속 인사고과 결과 최하위등급을 받아 역량향상프로그램 대상자가 된

근로자가 교육 후 현업에 복귀토록 하여 현업수행 평가를 실시하면서 평가자료로 교육대상자에게 주간 업무수행보고서, 월별 업무개선계획서, 개선제안보고서를 제출토록 하였는데 해당 근로자가 이를 일부 또는 전부 제출하지 않은 행위를 한 점, 교육대상자 39명 중 최하위를 기록한 점 등을 이유로 해당 근로자의 직무수행능력이 개선되지 않은 것으로서 정당한 해고사유라고 판단

□ 서울행판 2009.4.17, 2008구합34443 (대기발령 후 직권면직)

직무수행능력 부족을 이유로 대기발령을 받은 후에도 근무태도에 대한 반성의 빛이 없고 대기발령 사유를 해소시키기 위한 별다른 노력을 하지 않은 점, 업무시간 중 장시간 자리를 비우거나 조기 퇴근하는 경우가 여러 차례 있었던 점, 전직원을 대상으로 하는 교육프로그램에 허가 없이 불참하고 온라인 교육에서는 평균점에 미달하는 성적을 보인 점, 업무시간 중에 인터넷 골프·뉴스 사이트 등을 검색하고 업무에 관한 보고서나 기타 성과물 제출이 없었음을 들어 정당한 해고 사유로 인정

□ 서울행판 2000.12.15, 2000구21853 (대기발령 후 당연퇴직)

보직대기 기간 중 미수액을 감액하여 주고 대기기간을 연장해주면서 광고료 미수액의 수금을 독려하였고, 광고영업직의 업무성격상 직무능력의 회복이나 근무태도 개선을 위한 교육훈련 또는 특별한 연구과제를 부여하는 것이 현실적으로 기대하기 곤란한 반면, 해당 근로자들이 3개월여의 보직대기 기간 동안 미수금 회수 실적이 전무하고 가족들의 영업장에 대한 광고료마저 납입하지 않은 등 미수금의 회수나 광고수주 실적이 향상되었다고 볼만한 구체적인 성과나 노력을 보이지 못한 것은 해고 사유에 해당

나. 개선 기회 부여 불인정 사례

□ 대판 2007.2.9, 2006두18287 (징계해고)

감리업무에 종사하는 근로자가 기술적인 업무능력과 전문성 등은 있으나 대인관계상의 문제로 시공사와 잦은 업무상 마찰을 빚어 근로자가 회사에 다른 부서로 전보발령 해줄 것을 요청했으나 회사가 이를 거절하고 특별한 업무를 부여하지 않으면서 인사고과 결과 최하위등급을 받은 것을 이유로 해고한 것은 부당함.

□ 대판 2005.5.26, 2004두10401 (징계면직)

근로자가 팀원으로 발령된 후 주어진 직무를 수행하지 않은 것이 정당하다고 할 수는 없지만, 징계면직을 하기 위하여는 위 직무수행 거부가 사회통념상 고용관계를 계속할 수 없을 정도로 근로자에게 책임 있는 사유에까지 이르렀다고 할

수 있어야 할 것인데, 비록 회사가 연공서열에 따른 인사정책에서 탈피하여 직위와 직책을 분리하는 인사정책을 시행하였다고 하더라도 센터장이던 직원을 팀원으로까지 전보한 전례가 없어 근로자로서는 인사발령으로 인하여 근로의욕이 상당히 저하될 수밖에 없었던 것으로 보이고, 이러한 상황에서 회사는 근로자를 배려하여 마음을 추스를 시간적 여유를 주거나 근로의욕을 고취할 만한 조치를 전혀 취하지 않고 오히려 계속되는 사직권유나 기존 관행과 다른 좌석배치, 통상적인 업무량의 10% 정도만 부여하여 사실상 업무에서 배제하는 등으로 근로자의 근로의욕을 더욱 저감시켰고, 이와 같은 직무수행 거부에 이르게 된 경위를 고려하면 근로자의 직무수행 거부는 사회통념상 고용관계를 계속할 수 없을 정도에까지 이르는 사유라고 하기는 어려우므로, 회사가 센터장으로 근무하다가 팀원으로까지 전보된 근로자에 대한 배려를 전혀 하지 않은 채 단시일 내에 징계면직한 것은 재량권을 남용한 것으로서 위법함.

□ 대판 2004.10.28, 2003두6665 (대기발령 후 당연면직)

전산장비 도입 · 설치계약 실무업무를 처리한 근로자가 중대한 과실로 도입대상 전산장비(2대) 가격을 각 34,333,000원인데 68,666,000원으로 잘못 기재하여 재단에 동액 상당의 손해를 가한 것은 직위해제 사유에 해당함. 하지만 근로자가 직위해제처분 이후 자신의 실수로 재단에 손해를 입힌 사실을 시인하고, 피해액을 환수하기 위하여 변호사의 자문을 거쳐 납품업체의 담당자들과 수차례 접촉을 하는 등의 노력을 기울였음에도, 재단이 공식적으로 납품업체에 대하여 피해액 회수를 위한 어떠한 노력을 기울이지 않은 채 근로자에 대하여만 피해액의 변상을 요구하면서 근로자를 업무상배임 등의 혐의로 고소하고 근로자를 상대로 손해배상소송을 제기하여, 이에 따라 근로자가 재단에 손해를 변상하거나 구체적인 변상계획을 밝힐 수도 없게 되었으므로 직위해제처분 후 대기발령기간 중 근로자의 직무수행능력이 부족하거나 근무성적이 불량하다는 직위해제 사유가 계속한다고 볼만한 증거가 없음에도 불구하고 재단이 합리적인 사유 없이 근로자에게 직위를 부여하지 아니하다가 3개월의 기간이 만료하였다는 사유만으로 이 사건 당연면직처분을 한 것으로 보이므로 이는 징계권의 남용에 해당함(원심은 근로자의 잘못으로 인해 재단에 손해를 입힌 사실이 있음에도 불구하고 그 손해를 변상하거나 구체적인 변상계획을 밝히지 아니하여, 재단이 근로자를 상대로 손해배상 청구소송을 제기하여 그 소송이 계속 중인 사실을 인정한 다음, 근로자가 거액의 손해를 발생시킨 사실을 자인하고도 변상을 회피하고 그 환수책임을 피해자에게 전가시키고 있다고 보아 근로자의 직무수행능력 회복이나 근무성적 향상 등 직위해제사유가 소멸되어 마땅히 직위를 부여하여야 할 만한 사정이 없다는 이유로 대기발령기간 3개월이 만료됨을 사유로 행하여진 이 사건 당연면직처분이 위법하지 않다고 판단하였으나 대법원은 이를 파기 환송하였음).

□ 서울행판 2014.10.16, 2013구합22338 (대기발령 후 직권면직)

대기발령 기간에 진행된 역량개발프로그램이 사전계획에 의해 마련된 것으로 보이지 않은 점, 역량개발에 필요한 교육프로그램이 존재하지 않은 점, 역량개발 수행 실적에 대한 공정한 평가 등 시스템이 갖추어지지 않은 점, 업무복귀에 필요한 교육이 아닌 단순 하역작업이나 하청 용역회사에서 필요한 운전기술과 지게차 운전면허 취득을 수행과제로 제시하는 등 역량을 개발하여 업무에 복귀시키는데 진정성이 없거나 매우 미흡한 것으로 보이므로 부당함.

□ 대전고판 2015.10.15, 2015누10412 (대기발령)

업무수행능력이 부족하여 대기발령 사유에 해당한다고 인정되지만, 영업직 부장으로 근무하였던 근로자에게 현장직무실습이라는 명목으로 단순 노무와 청소업무를 부여한 것은 근로자의 기존 직무범위나 직무전환을 통해 담당하게 될 C/S 업무의 내용이라고 보기 어렵고 근로자의 역량개발이나 직무전환에 도움이 되지 않는 점, 매주 면담에서도 직무전환에 대한 협의가 아닌 직무전환을 해줄 수 없으며 사직하지 않을 경우의 불이익 등에 대해 이야기하는 등 대기발령이 근로자를 퇴사시키기 위한 압박수단으로 보이는 점, 노동위원회에서 부당 대기발령으로 판정받은 후에도 추가 교육이나 배치 없이 전화기와 인터넷 사용이 불가능한 상태로 방치한 점 등을 이유로 부당한 대기발령으로 판단

(3) 요약 및 검토

○ 직무수행능력 부족이 해고 사유로 인정되더라도 사용자는 해고에 앞서 사업의 종류 · 규모, 근로자의 직종 · 능력 · 경력 · 지위, 기업에서 근로자의 배치 · 이동의 실태 등을 종합적으로 고려해 가능한 범위에서 해당 근로자에게 재교육, 재배치 등을 통해 직무수행능력을 개선할 수 있는 기회를 부여하여야 함.

○ 계약법적 관점의 계속성원리나 유연성원리 외에도 근로계약 고유의 규범적 근거로서 해고가 근로자의 생존과 인격에 미치는 부정적 영향을 최소화하고, 노동시장에서의 근로자와 사용자의 비대등성을 개선하기 위해서는 해고에 대한 일정한 규제가 불가피하다는 점 등을 그 근거로 들 수 있음. 이에 판례는 직무수행능력 부족이 인사고과 결과나 그 밖의 자료에 의해 확인되는 경우라도 곧바로 해고할 수 있는 것은 아니며, **재교육이나 직무재배치 등 가능한 방법을 통해 개선의 기회를 충분히 부여했음에도 개선되지 않은 경우**에 해고의 정당성이 인정된다고 하여 사용자의 배려의무를 중시함.

○ 개선의 기회는 특정 근로자의 퇴출(사직, 해고)을 목적으로 한 것이 아니라 직무수행 능력의 향상이 진정한 목적으로 근로자의 능력을 향상시키는 조치가 구체적이고 실질적으로 취해져야 하며, 능력향상프로그램 등의 내용이 미비하고 졸속으로 운영되거나 제반 사정에 비추어 볼 때 근로자의 능력을 개발하여 업무에 복귀시키는데 진정성이 없는 경우에는 해고의 정당성이 부정됨.

○ 판례는 근로자도 직무수행능력 부족을 이유로 대기발령이나 재교육, 재배치를 받았으면 업무수행능력을 향상시키기 위한 노력을 기울여야 할 것인데 그러한 노력을 하지 않은 경우에는 해고 사유가 인정된다고 보고 있음. 특히 결근이나 무단이탈 등 근태가 좋지 않은 경우, 재교육에 무단으로 불참하거나 방해 거부한 경우, 재교육이나 업무와 관련한 자료 제출 지시를 이행하지 않은 경우 등에 대해서는 근로자의 직무수행능력 부족이 개선되지 않은 것으로 인정한 사례가 있음.

5. 나오며

○ 직무수행능력 부족이 정당한 해고 사유로 인정되려면 객관성, 중대성, 지속성을 갖고 있어야 한다고 요약할 수 있음. 기업이 사업의 기능을 유지하고 고유의 목적을 달성하기 위해서는 근로자의 직무수행능력이 현저히 부족한 경우 해고가 불가피하게 됨. 근로자의 직무수행능력이 부족하여 근로계약의 체결과 존속의 기초가 상실될 정도에 이르렀음에도 해고하지 못한다면 계약자유의 원칙을 전면 부정하는 결과가 될 것임. 현행 근로기준법의 해고에 대한 규제가 객관성, 중대성, 지속성이 인정되는 직무수행능력 부족의 경우에도 해고할 수 없다는 것을 의미하지는 않음. 판례도 직무수행능력 부족을 해고의 사유로 보고 있음.

○ 그동안 실무에서 해고를 징계의 한 종류로 이해하면서 직무수행능력 부족을 많은 경우 징계해고의 문제로 다루었고, 판례에서도 통상해고나 일반해고라는 용어를 사용하면서도 이에 대한 구체적인 개념이나 내용에 대해서는 더 이상의 언급이 없었으나, 최근 능력과 성과 중심의 인적자원관리가 확산됨에 따라 채용 · 배치 · 승진 · 임금 · 퇴직 · 해고 등 인적자원관리 전반에 걸쳐 근로자의 직무능력 향상과 직무수행능력이 부족한 근로자에 대한 관리의 중요성이 증대하고 있는 바, 충분한 검토와 논의를 통해 관련 법적 쟁점과 판단기준이 체계적으로 제시된다면 불필요한 분쟁을 사전에 예방하는데 도움이 될 수 있을 것임.

○ 고용노동부 ‘직무능력과 성과 중심의 인력운영 가이드북’의 방향?

* 내비게이션 / 표지판 · 신호등

* 제반사정 · 참고사항 / 요건

* 규정, 평가대상 · 기준 · 방법 · 공개, 교육훈련, 배치전환

○ 다른 한편으로 근로자의 직무수행능력이 부족한 경우 해고될 수 있는 가능성이 있는데 해고의 최후수단성의 원칙에서 본다면 근로자의 입장에서도 해고 대신 임금이나 직위 등을 재조정하여 직무수행능력에 상응하는 임금을 지급받거나 능력에 걸맞은 직위 · 직책을 부여받고 근로관계를 지속하는 것이 요구될 수 있으므로 변경해고제도에 대해서도 검토할 필요가 있음. 독일의 경우 해고제한법 제2조와 제4조에서 변경해고제도를 규정하고 있는데, 사용자의 변경해고에 대하여 근로자는 승낙, 거절, 유보부 승낙 중 한 가지를 선택할 수 있음. 변경해고제도가 없다면 사용자의 근로조건 변경에 대해 근로자는 그 정당하지 않다고 생각하더라도 이를 감수하고 근로를 계속하던지(승낙) 아니면 해고된 후 소송으로 해고의 정당성을 다툴 수밖에 없으나(거절), 유보부 승낙제도에 따라 근로관계를 계속하면서 근로자가 근로조건 변경에 대해 다툴 수 있음.[6] 변경해고제도는 해고 대신 근로관계의 존속을 전제로 근로조건의 변경가능성을 인정한다는 점에서 의의가 있음.

6) 이승욱, ‘독일의 변경해지제도’, 『노동법학』(제14호), 2002, 242면 이하 참조(독일의 변경해고제도와 관련하여 해고제한법의 목적이 근로관계의 존립 보호를 넘어서 근로계약의 내용 보호까지 확대되었다고 평가한다).

종 합 토 론

토 론 문

김희성 (강원대학교 법학전문대학원 교수)

1. 고용노동부가 2015년 12월 30일에 발표한 직무능력과 성과 중심 인력운영 가이드북(안)에 대해

해고제도의 개선방향으로는 노동시장의 유연성을 제고하면서 비정규직 근로자의 고용안정과 근로조건 보호를 조화시키는 방안으로 근로기준법의 해고제도 전반에 대한 합리적 개선방안을 마련할 필요가 있다.

주지하다시피 그동안 해고 제도에 대한 논의는 간헐적으로 진행되어 왔으나, 집중적이고 구체적인 논의는 거의 이뤄지지 못하였다. 따라서 이제는 해고 제도를 둘러싼 법리적 쟁점에 대한 종합적인 분석 및 객관적인 평가를 통해 해고제도의 합리적인 개선방안을 제시할 필요가 있다.

특히 이제는 직무와 능력 중심의 인적자원관리(성과주의적 인적 자원관리)가 확산되면서 기업의 인적자원관리 방식도 근로자들이 창출해 내는 지식과 이들이 가진 역량을 기업 경쟁력에 어떻게 최대한 접목케 하느냐의 관점으로 변모되고 있다. 이것은 저성과자의 관리 문제와 직결되는데, 정년연장에 따른 고령화 시대에 진입하면서 여전히 낮은 고용유연성과 이에 따른 저성과자 관리가 중요 쟁점으로 떠오르고 있다. 즉 장기고용관행에서 성과주의 인사관리체제로 전환하는 추세를 고려한 해고제도의 정비 필요성이 제기되며, 직무 · 성과 등 능력중심의 인사관리 전개 · 확산으로 성과 · 근무성적 · 적격성 등을 이유로 한 해고가 증가하는 추세에 따라 그에 관한 법적 규제도 명확히 할 필요성이 있다. 해고를 포함한 인사관리시스템은 기업의 경쟁력을 위하여 자체적으로 계속해서 수정 · 변화될 수밖에 없으며, 그에 따라 법적 규제의 예측가능성은 노사 모두에게 반드시 확보되어야 할 기본 전제이다.[7)]

우리나라에서는 해고를 규제하는 독립적인 단행법률은 존재하고 있지 않고, 해고규제에 관해서는 현행 근로기준법 제23조 내지 제26조 및 제28조 이하에 규정되어 있다. 근로기준법에는 정당한 이유 없는 해고를 제한하는 일반적 해고제한조항(제

7) 박지순, 노사정위원회 토론회 발제문, 2015.9.7. 참고.

23조), 경영상 이유에 의한 해고의 제한조항(제24조), 해고하는 경우 일정기간 전에 해고예고하도록 하는 해고예고제(제26조) 및 부당하게 해고를 당한 경우 구제받을 수 있는 부당해고구제조항(제28조)이 규정되어 있다. 이러한 해고규제규정은 그 내용이 포괄적이고 추상적이어서 해고규제법리는 판례와 학설을 통해서 발전·형성되었다.

판례는 근로자의 책임 있는 사유로 인한 해고 - 주로 이는 징계해고로 나타남 - 의 경우와 일신상의 사유로 인한 해고의 경우로 구분하여 판지를 달리 구성 적용하는 것으로 보인다. 따라서 판례는 해고의 유형을 통상해고와 징계해고 그리고 정리해고로 구분하여 판단하는 것으로 평가되며, 통상해고의 경우는 근로자의 책임 있는 사유가 없이 근로관계를 지속할 수 없는 장애사유가 발생한 경우를 대상으로 하며, 징계해고는 근로자의 책임 있는 사유를 전제로 해고의 정당성 여부를 판단하는 입장을 견지하고 있다. 이때 징계해고 사유대상은 근로자가 복무질서를 위반하는 등의 경우와 근무성적의 불량 등 근로계약에서 요구되는 업무수행능력부족과 같은 행태도 함께 포함하여 판단하고 있는 점이 특징적이다.[8)]

그런데 현행 근로기준법상 해고제한규정(제23조 제1항)은 해고를 징벌의 하나로 기술하고 있어 통상해고에 대해서는 실질적으로 법적 공백상태이다. 이로 인해 위에서 본 바와 같이 업무능력 부족 등 통상해고의 다수 사례가 실무상 징계해고의 양태를 띠고 있고, 판례도 이를 징계처분의 대상으로 수용하여 정당성 여부를 판단하고 있어 사법적 판단에 혼란이 발생하고 있다.

현행 근로기준법상 해고규정은 해고를 징벌의 하나로 기술하고 있어 징계해고가 아닌 통상해고 가능성에 대해서는 법적인 논란과 현장에서의 혼란이 있다. 이에 따라 현장에서 저성과 등의 사유로 해고의 가능성과 정당성을 둘러싼 혼란과 갈등이 증가하고 있어 노동시장의 유연성을 제고하면서 비정규직 근로자의 고용안정과 근로조건 보호를 조화시키는 방향으로 해고제도 전반의 개선논의도 필요하다.

특히 "직무능력이 결여되었거나 근무성적이 부진한 자"의 해고 문제는 우리 해고법제의 구성에 항상 부족한 영역으로 인식해 온 근로자의 능력이나 적격성에 따른 일신상 사유에 대한 정당성 판단기준을 논의의 대상으로 하는 것이다. 이러한 문제를 다루는 작업은 단순히 해고법체계에 대한 이론적 근거 내지 의미를 밝히는데 목적이 있는 것이 아니라 "직무능력이 결여되었거나 근무성적이 부진한 자"라는 구체적인 문제를 해결하기 위해 필요한 기준을 제시하기 것이고, 이를 통해 "직무능력이 결여되었거나 근무성적이 부진한 자"에 대한 해고의 정당성을 판단하는데 있어서 고려되어야 할 요소를 발견할 수 있다는 점에 의의가 있다.

---

8) 박종희. "현행 해고보호제도의 체계적 이해와 해석에 관한 연구", 「안암법학」 제44호, 2014, 450-451면.

우선 “직무능력이 결여되었거나 근무성적이 부진한 자”에 대해서는 분명히 근로자 스스로 충분한 노력을 통하여 정상적인 직무능력의 회복을 꾀할 수 있는 기회가 제공되어야 하며, 이러한 기회 제공에도 불구하고 근로자가 저성과를 회복하지 못한 경우에는 해고가 고려되어야 한다. 이때 직업능력향상훈련이나 직종전환을 통한 해고회피조치 등까지 포함하여 보다 완화된 수단의 활용가능성들도 함께 검토해야 한다.[9] - 이게 정당성 기준

최근 직무와 능력 중심의 인적자원관리(성과주의적 인적자원관리)가 확산되면서 기업의 인적자원관리 방식도 근로자들이 창출해 내는 지식과 이들이 가진 역량을 기업 경쟁력에 어떻게 최대한 접목하게 하느냐의 관점으로 변모되고 있다. 특히 정년연장에 따른 고령화 시대에 진입하면서 여전히 낮은 고용유연성과 이에 따른 “직무능력이 결여되었거나 근무성적이 부진한 자” 관리 등 합리적인 인력운영이 중요 쟁점으로 떠오르고 있다. 따라서 단순히 해고제도 뿐만 아니라 채용에서부터 해고까지 인력운영 전반에 대해 일자리와 고용안정의 관점에서 문제를 점검하고 어떻게 개선해 나가야 할지를 검토하여야 한다. 먼저, 채용-평가-능력개발・보상-근로관계 해지 등 합리적인 원칙과 노사가 알아야할 법・제도와 쟁점에 대해 정확하게 알려주어 인력운영의 투명성과 예견 가능성을 높여야 한다. 특히 해고의 기준과 절차의 불확실성으로 인한 분쟁이 증가하고 있는 상황에서 “직무능력의 결여나 근무성적의 부진”등 통상해고의 유형과 정당성이 인정될 수 있는 개괄적인 범위에 대한 가이드라인 마련을 위하여 노사정 간 논의와 고민이 필요하다. 다만, 이러한 가이드라인 등이 법원의 판단과 다를 경우 그 효력을 인정받기 어려우므로 그 내용은 법과 판례에 따라 마련되어야 한다.

이 점에서 고용노동부가 2015년 12월 30일에 발표한 직무능력과 성과 중심 인력운영 가이드북(안)은 그 의의가 크다고 할 것이다.

판단컨대 시장 환경이 점차 경쟁적으로 변화함에 따라 업무 부적격자 등에 대한 통상해고 필요성이 점차 증가하고 있는바, 정부 차원에서 통상해고의 유형과 정당성이 인정될 수 있는 개괄적인 범위에 대한 지침(가이드라인) 을 마련함으로써 불확실성을 완화하여 기업이 통상해고를 활용할 수 있는 길을 넓혀 주는 조치가 필요할 것이다. 특히 이러한 지침 내지 가이드라인은 법원이 “직무능력이 결여되었거나 근무성적이 부진한 자”에 대한 해고문제를 판단함에 있어 유용한 참고가 될 것이다. 따라서 통상해고의 사유 안에 업무능력 결여 등에 따른 해고시 정당성 판단

9) 박지순 교수는「결국 성과형 해고의 기준은 성과미달성이나 성적불량, 업무부적격성을 판단하는 평가기준이 얼마나 합리적이고 객관적인가, 그 기준에 해당 근로자에게 공정하게 적용되었는가? 해당 근로자의 고용을 유지하기 위하여 사용자가 얼마나 구체적이고 실질적인 조치를 행하였는가? 근로자는 그 과정에서 성실하게 능력개발과 업무적격성 개선을 위하여 노력을 기울였는가? 등을 근거로 정당성을 판단할 수 있다」고 한다(노사정위원회 토론회 발제문, 2015.9.7.).

의 핵심요소로 객관적이고 공정한 평가가 중요함을 설명하고 구체적으로 ▲평가제도 설계 ▲평가방법의 타당성 ▲평가의 실행의 신뢰성 등에 대한 내용을 명확히 하는 방식으로 가이드라인을 정한 것은 의미가 있는 것이라고 할 수 있다. 또한 평가의 절차의 까다로움 등이 특징적으로 공정하고 객관적인 평가와 이를 토대로 한 능력개발을 위한 교육훈련, 배치전환의 기회 등을 부여했음에도 불구하고 업무능력 또는 성과개선의 여지가 없거나, 업무의 상당한 지장을 초래하는 경우 업무능력 결여, 근무성적 부진 등을 이유로 통상해고를 할 수 있도록 한 점에서 노동계 일각에서 주장하는 쉬운 해고를 할 수 있도록 하는 가이드라인과는 그 존재의 평면을 달리하는 것이라 할 수 있다.

다만 고용노동부의 가이드라인이나 지침 등으로 통상해고의 유형 등의 기준 속에 업무 부적격자 등에 관한 내용을 마련할 수도 있겠지만, 이러한 가이드라인이나 지침이 법원의 판단과 다를 경우 그 효력을 인정받기 어려울 수 있다는 문제도 여전히 있기 때문에 중장기적으로 근로기준법상의 해고제한규정의 개정(해고법제의 개선)과 더불어 시행령의 개정을 통해 마련하는 것이 바람직할 것으로 보인다.

아무튼 결론적으로 현행 해고관련 규정의 불명확성을 해소하고 법체계의 미비점을 개선하기 위해서는 해고제도에 관한 논의를 충분히 하고, 해외사례도 참고하면서 직무·성과 중심의 새로운 인사관리제도에 적합한 해고법제로 재구축해야 졸속입법을 피하고 지속가능한 안정적인 입법이 가능할 것이다.[10)]

2. 고용노동부가 2015년 12월 30일에 발표한 취업규칙 해석 및 운영 지침 개정안에 대해

2016년부터 '고용상 연령차별금지 및 고령자 고용촉진에 관한 법률'을 통해 근로자의 정년을 60세 이상으로 정하는 것이 의무화 되었고 이에 따른 임금체계의 개편 등이 법제화되어 있다. 문제는 이 법 제19조의 제2항에 임금체계와 관련해 사업 또는 사업장의 여건에 따라 임금체계개편 등 필요한 조치를 취하여야 한다는 모호한 표현으로 이를 둘러싼 많은 논란이 제기되고 있다. 따라서 현실에서 임금피크제를 도입하려면 근기법 제94조 제1항 단서의 '취업규칙의 불이익변경시 근로자집단의 동의를 받아야 한다'는 규정과 조화로운 해결방법을 모색하여야 한다.

특히 정년연장과 임금체계 개선(임금피크제 도입)과 관련된 쟁점을 검토하며, 향후 이와 유사한 쟁점이 발생할 경우 노사 간의 분쟁을 예방하고, 당사자 간의 근로관계를 보다 명확히 할 수 있도록 합리적인 대안을 제시할 필요가 있는데, 2015년

10) 동지: 박지순, 노사정위원회 토론회 발제문, 2015.9.7.

12월 30일 고용노동부는 취업규칙 해석 및 운영 지침 개정의 형식을 빌려 추진하는 것으로 발표했다. 즉, 판례가 근로자의 동의를 받지 않은 취업규칙 변경에 대해, 사회통념상 합리성이 있는 경우 예외적으로 변경의 효력을 인정한다고 판단하고 있는 만큼 정년에 60세에 따른 임금피크제 도입시 이를 적용하여 판단하되, 판례가 제한적으로 엄격하게 해석하고 있는 점을 감안하여, 6가지의 요소를 종합적으로 판단하는 기준을 제시하였다.

생각건대 취업규칙의 변경에 따른 임금피크제의 실시 자체가 일응 모두 불이익변경에 해당한다 하더라도 근로자측이 임금피크제의 실시에 동의하지 않는 경우에는 기본적으로 사회통념상 합리성 판단이 필요하며, 이 경우에는 고용노동부가 제시한 6가지의 요소를 종합적으로 판단하여 사회통념상 합리성 인정여부를 판단하는 것은 긍정적인 측면이 있다고 할 것이다.

그런데 이와 같이 고용부 지침 및 지배적인 해석론에 따른다 하더라도 합리성이 있는 취업규칙 불이익변경을 허용하는 요건을 법령에 명시하여 시행하지 않고 지침의 형식으로 시행하는 것은 자칫 후일 사법부의 판단에 따라 예기치 못한 결론을 얻게 되는 등으로 제2의 통상임금 사태와 같은 문제에 봉착할 수 있다. 따라서 법령을 통한 취업규칙 불이익변경 법리를 명확하게 구비하여 시행될 필요가 있고, 법령 개정 수단이 가장 안정적이고 명확한 방안이라 할 수 있을 것이다.

토 론 문

박우성 (경희대학교 경영대학 교수)

1. 직무 능력과 성과중심의 인적자원관리

능력과 성과에 기초한 인적자원관리의 혁신은 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. 우리나라 기업들의 생산성과 경쟁력을 위해서 반드시 이루어져야 할 중요한 정책적 과제입니다. 제도적 기반정비를 위해 정부의 역할도 중요하지만 기본적으로는 기업들이 적극적으로 이러한 변화를 추구하고 실현시켜야 합니다. 종업원이나 노동조합의 입장에서도 연공보다는 능력과 성과가 더 공정하고 합리적인 기준입니다.

다만, 연공을 무조건 나쁜 것으로 백안시할 필요는 없습니다. 경력초기에는 근속년수가 증가함에 따라 직무능력이 상승하는 상관관계를 가지기도 하고 연공의 영향이 지나치게 강하지만 않다면 근속을 고려하는 것이 때로는 근로자들의 직장생활의 즐거움이나 동기부여를 촉진하는 요인이 되기도 합니다. 현재 필요한 것은 지나치게 강한 연공성을 완화하거나 통제하면서 인적자원관리의 기본을 능력과 성과 위주로 재편하는 것입니다.

2. 임금피크제와 임금체계 개편

정년연장이 법을 통해 급작스러운 방식으로 실현되었기 때문에 우리나라 기업들이 이에 대한 준비가 제대로 되어있지 못한 것이 사실입니다. 특히 정년이 늘어나게 되는 고령인력으로 인해 인건비 부담이 크게 증가하게 되기 때문에 임금피크제가 이에 대응하기 위한 매우 효과적인 수단이라는 점에는 이론의 여지가 없습니다.

그러나 임금피크제가 정책적 과제의 전부일 수는 없습니다. 임금피크제가 인건비 부담을 크게 줄여주는 것은 사실이지만 부작용도 적지 않습니다. 일의 특성이나 개인의 역량과 전문성, 동기부여 수준이 상이함에도 불구하고 일정한 연령에 도달하면 일률적으로 임금을 깎는다는 논리 자체가 문제점을 내포하고 있으며 자칫 고령인력의 사기를 크게 떨어뜨려서 조직분위기나 생산성에 부정적 영향을 미칠 가능성이 큽니다.

따라서 임금피크제를 확산시켜서 도입율을 높이는 것에 만족할 것이 아니라 근본적인 임금체계 개편을 신속하게 추진해야 합니다. 달리 말하자면, 장기적으로는 굳이 임금피크제를 도입할 필요가 없도록 임금이 결정되는 과정과 기준을 바꾸어야 합니다. 이를 위해서는 임금이 결정되는 과정에서 연공의 효과를 줄이는 대신 역할이나 직무, 성과 등에 따라 임금이 결정되는 체계로의 이행이 필요합니다. 입사 이후부터 근속이 아니라 능력과 성과, 혹은 일의 가치나 책임 정도에 따라 임금이 결정되어야 한다는 것입니다. 그렇게 되면 근속이 오른다는 이유만으로 임금이 오르게 될 일이 없어질 것이고 돈을 많이 받는 직원들의 경우 중요한 일이나 직책을 맡고 있거나 높은 실력이나 성과를 보이고 있을 터이니 회사의 입장에서도 이들의 임금을 깎거나 내보내야 할 필요성이 없게 됩니다. 근속에 따라 임금이 크게 영향을 받는 것을 없애고 능력, 성과, 역할, 책임 등의 합리적인 기준에 따라 임금을 결정하자는 것이 임금체계 개편이 추구해야 하는 기본 방향입니다.

3. 통상해고 요건의 명확화

업무능력 결여 근무성적 부진을 이유로 한 통상해고 요건을 명확하게 하는 것은 중요한 과제입니다. 해고를 둘러싼 갈등을 해결하기 위해 소요되는 시간과 노력을 줄이는 한편 우리나라 기업의 인적자원관리가 능력과 성과중심으로의 이행하는 것을 촉진하는 중요한 영향을 미칠 것으로 생각됩니다. 그러나 통상해고가 남용되지 않도록 엄격한 기준과 점검 장치들이 필요한 것도 사실입니다. 특히 노조가 없는 중소기업의 경우 남용 가능성이 매우 높습니다.

업무능력이나 근무성적 부진을 이유로 한 해고와 관련해서 기업들이 사전에 철저하게 준비해야 하는 것이 바로 합리적인 평가제도입니다. 평가제도가 합리적으로 설계되어야 하고 평가에 대한 신뢰나 수용성이 중요합니다. 그러나 역설적으로 평가에 대한 신뢰가 어느 기업에서나 매우 낮은 것이 현실입니다. 따라서 합리적인 평가 제도를 구축하는 한편 평가의 신뢰성을 높이려는 노력이 절실히 필요합니다.

그 중의 하나가 절대평가입니다. 해고의 공정성을 확보하기 위해서는 절대평가가 바람직한 것이 사실이지만 현실적으로 절대평가를 운영하기가 쉽지 않습니다. 절대평가를 하기 위해서는 임금인상 예산이나 승진기회 등 자원의 여유가 있어야 하고 평가자들의 평가 역량이 뒷받침되어야 하기 때문입니다. 절대평가를 실시하는 기업들을 찾아보기 힘든 이유입니다. 전반적인 평가제도가 상대평가에 기초하고 있다고 해도 적어도 업무능력이 현저히 떨어지는 최하위 고과등급에 대해서는 상대평가가 아니라 절대평가를 하는 것이 바람직합니다.

평가결과가 해고자 선발만이 아니라 보상이나 교육훈련에도 적용되는 것이니만큼 향후 평가제도를 합리적으로 만들기 위한 기업들이 지속적인 노력이 중요합니다. 특히 제도 설계 뿐 아니라 운영과정에서 성과관리의 관점에서 현장 관리자나 리더들의 피드백과 코칭 역량이 매우 중요합니다.

토 론 문

오계택 (한국노동연구원 임금직무혁신센터 소장)

O 해고의 양극화

- 현재 우리나라에서는 ‘너무 쉬운 해고’와 ‘너무 어려운 해고’가 동시에 발생하고 있음.
- 따라서, 현재 우리나라 노동시장에서 필요한 것은 ‘공정한 해고’이며, 이를 위해 해고의 기본적인 기준 및 절차 등을 명확하게 하여 우리나라 노동시장 어디에서 일하든지 같은 기준과 절차에 의해 해고가 이루어질 수 있도록 하는 장치 마련이 필요
- 결국, 해고의 양극화도 우리나라 노동시장 양극화 현상의 한 요소로 인식하고 서로 비슷한 일을 하는 근로자들이 서로 비슷한 환경에서 근무할 수 있도록 하는 노동시장 양극화 해소방안의 하나로 접근할 필요

O 기업의 인적자원관리의 기본원칙

- 너무나 당연한 것이지만 기업에서 인력을 채용하는 것은 해당 근로자가 가지고 있는 업무능력을 효율적으로 활용하기 위한 것임.
- 따라서, 기업은 해당 근로자가 가지고 있는 업무능력을 파악하고, 평가하고, 활용하는 과정에서 이에 대한 책임을 가지고 있음.
- 퇴직관리 과정에서 기업이 퇴직대상 근로자에 대해 직업능력개발과 배치전환을 통한 적합직무 조정 등의 과정을 거치도록 하는 것은 이러한 취지임.
- 가장 기본적인 원칙은 근로자를 업무능력에 기반하여 채용한다면 퇴직관리까지 업무능력에 기반하여 할 수 있도록 제도들 간의 연계성 및 일관성을 유지하도록 하는 것임.

O 직무능력에 대한 평가기준

- 직무능력 및 성과 중심의 인력운영을 위해서는 직무능력 판단기준을 명확하게 할 필요가 있음.

- 미국의 경우, 차별관련 법제도들이 정착되면서 실질적 업무능력(BFOQ: Bona Fide Occupational Qualification)이라는 판례상의 관행을 통해 업무능력에 대한 기준 등이 명확해지고 기업들도 각 직무 혹은 직종별 업무능력 기준 및 평가제도를 발전시킨 경험이 있음.
- 우리나라도 직무능력 중심의 인사관리 정착을 위해서는 직무능력 판단기준 및 평가기준 마련이 시급한 상황이고, 이를 위해 고용차별 등의 판결에서 직무능력을 고용상의 차별 여부에 있어 중요한 요인으로 정착시킴으로써 기업들의 자연적인 직무능력 판단기준 강화를 유인할 필요가 있음.

O ‘통상해고’에서의 정당한 이유

- 현재의 노동법상에서는 통상해고를 위해 정당한 이유가 있어야 하는데 이 ‘정당한 이유’가 현재로서는 모호한 개념이기 때문에 부당해고에 대한 소송이 많은 것으로 판단됨.
- 따라서, 어느 정도 정당한 이유가 통상해고를 위한 정당한 이유가 될 수 있는지 등에 대한 법적 및 사회적 합의가 필요.
- 이러이러한 행위를 하였을 경우 해고의 대상이 될 수 있다는 방식의 positive 방식이든 이러이러한 행위를 하지 않으면 해고의 대상이 아니라는 방식의 negative 방식이든 어떤 방식을 통해서든 해고 기준에 대한 명확성을 높이지 않으며 제도 시행상의 혼란과 근로자들의 불필요한 불안정 등을 야기할 가능성

O 평가제도의 객관성

- 대부분의 기업들은 성과평가와 역량평가를 통해 평가제도를 운영하고 있으며, 성과평가는 KPI, MBO, 갯수급 등 다양한 방식을 통해 어느 정도 지표화 및 양화가 이루어지고 있음.
- 하지만, 모든 업무성과를 양화하기 어려운 측면이 있으며, 특히 근로자의 역량의 기업의 미래발전 등에 중요하게 작용함으로써 현재의 직무에서의 성과뿐만 아니라 미래의 잠재적인 직무에서의 역량 가능성도 평가요소로 포함하는 경우가 많음.
- 역량평가는 주로 상급자 등을 통해 주관적인 방식으로 이루지고 있으며, 다만 BARS나 BOS 등의 척도 지표화 방식을 통해 어느 정도의 객관성을 담보하고자 노력하고 있음.
- 일반적으로 생산직은 성과의 측정이나 양화 등은 용이하지만 전체 생산 공정

에서 개별 근로자의 재량권이 없는 상황에서 개별평가의 유용성에 대한 의문이 제기되고 있으며, 사무직이나 관리직의 경우 개별평가의 필요성은 높으나 척도화 및 평가지표의 구성에 어려움이 있음.

- 하위 직급의 경우에는 주로 상급자가 지시하는 업무내용을 실행하는 역할을 담당하므로 성과결과에 있어서도 개별 근로자가 책임질 수 있는 영역은 상대적으로 협소할 수 있고, 고위직급의 경우에는 자신의 재량적 판단에 의해 성과결과가 영향을 받을 수 있는 가능성이 높아진다고 볼 수 있음.
- 따라서, 직종별 및 직급별로 평가의 기준 및 평가의 성격 등이 달라질 수 있으므로 평가제도의 객관성 판단에서 이에 대한 고려도 필요

O 평가방법의 타당성

- 서구 국가들의 경우에도 상대평가 방식을 도입하여 경쟁에 입각한 인사관리를 실시하였으나 최근에는 다시 절대평가 방식으로 회귀하는 경향
- 가장 대표적인 실례는 GE의 상대평가를 통한 인사관리 정책으로 GE는 상대평가 방식을 통해 하위 10%를 지속적으로 퇴출시키는 인사관리 정책을 가지고 있었음.
- 하지만, 이러한 방식이 가지고 있는 약점 특히 근로자의 사기 등에 대해 미치는 부정적 영향 등이 커지면서 퇴근 이러한 정책을 포기한 것으로 알려져 있음.

O 평가의 신뢰성

- 복수의 평가자, 다단계 평가, 근로자 이의제기 기회 제공 등을 통해 평가의 대상이 되는 근로자들의 제도에 대한 수용성은 높아질 수 있지만 이를 통해 평가제고의 타당성이나 신뢰성을 담보할 수 있는 것은 아님.
- 결국 기본적으로 평가제도는 완전히 객관적이고 완전히 공정한 평가제도라는 것은 사실상 불가능하고 얼마나 편의(bias)의 가능성을 줄이고 근로자들의 동의와 수용성을 얻어 낼 수 있는가가 관건이라고 할 수 있음.
- 따라서, 평가제도를 객관적인 조건에 따라 판단하기는 어려우며 얼마나 구성원들이 수용하고 이를 받아들일 수 있는가 여부가 제도운영의 핵심적인 요인이 될 것임.

O 취업규칙 변경에 있어서의 '사회통념상 합리성 인정'

- 이 또한 모호하고 서로 다르게 그리고 넓게 해석될 수 있는 여지를 가지고 있는 조항

- 문제는 이 ‘사회통념상 합리성’을 누가 인정할 것인가의 문제인데 현재 취업규칙 등에 대한 행정지도는 고용노동부 근로감독관들이 담당하고 있으므로 근로감독관들이 ‘사회통념상 합리성’을 판단해야 한다는 문제에 직면하게 됨.
- 하지만, 행정해석과 법원의 판결이 다르게 되면 제2의 통상임금 사태가 될 가능성도 가지고 있음.
- 취업규칙을 임금피크제 도입에 한정하여 본다면 결국 임금피크제를 도입하기 위해 취업규칙을 변경하는 것은 사회적으로 합리적인가라는 질문이 될 것임.

토 론 문

이철행 (전국경제인연합회 고용복지팀 팀장)

□ 정부 양대 지침이 노동계가 주장하듯 '쉬운 해고'를 가능하게 하고, '근로자의 일방적 희생을 강요'하는 것인가에 대해 검토하고자 함.

1. 통상해고 지침(초안)에 따르면 사용자가 저성과자를 쉽게 해고할 수 있는가?

1) 지침(초안)은 법원이 부당해고가 아니라 정당한 해고라고 인정한 판례에서 '정당성 요건'으로 적시한 사안을 모두 충족할 것을 권고함.

○ 지침에서는 통상해고를 위해서는 업무능력 부족이 해고사유라는 것이 취업규칙 또는 단체협약에 명확히 규정되어야 하고, 객관적·합리적 평가가 이루어져야 하며, 교육훈련 전환배치 등의 개선기회를 부여했음에도 업무능력이 개선되지 않아 사회통념상 근로관계를 유지할 수 없게 되었다는 것을 보여줄 것을 요구

<통상해고 정당성 판단 지침>

판단기준	내 용
① 사유	▪ 업무능력 부족이 해고 사유라고 취업규칙, 단체협약에 규정
② 평가	▪ 객관적·합리적 기준에 의한 공정한 평가 - (평가대상) 근로자의 업무능력 또는 근무실적 - (평가기준) 평가항목 세분화·구체화, 평가기준의 객관성 등 - (평가방법) 평가방법의 타당성, 평가기준과 절차의 준수
③ 회피노력	▪ 교육훈련, 배치전환 등 개선기회 부여
④ 대상자 선정	▪ 업무능력 부족으로 사회통념상 근로관계를 유지하기 어려움

2) 법원이 정당한 해고라고 판결한 판례를 보면, 정부 지침(초안)에서 열거한 4가지 정당성 판단 지침을 충족하지 못하는 경우가 대부분

○ ‘업무부진자 해고’에 대한 판례를 보면, 업종에 따라 해고에 이르게 된 상황이 다양하며, 교육훈련·전환배치 등의 기회 부여를 꼭 할 수 있는 것은 아님.

<주요 해고 판례에 대한 노동위원회·법원 판결 현황>

No.	구분 (선고일)	지노위	중노위	행정법원	주요내용
1	OO일보 (‘00.12월)	구제신청 기각	구제신청 인정	구제신청 기각	직무수행능력 부족으로 대기발령을 받고 업무수행능력 향상 노력을 하지 않아 면직처분한 것은 적법함
2	OO방송 (‘04.12월)	구제신청 기각	구제신청 인정	구제신청 기각	2회 연속 인사고과에서 최하위등급을 받아 징계해고한 것은 징계권남용 아님
3	OO협동조합 (‘06.02월)	구제신청 기각	구제신청 기각	구제신청 기각	직무수행능력 부족으로 대기발령을 받고 업무수행능력 향상 노력을 하지 않아 면직처분한 것은 적법함

(1) OO일보 사건 (서울행법 2000구21853)

① 사유: 업무능력 부족이 해고 사유라는 것이 취업규칙, 단체협약에 규정됨.

- ‘인사규칙’에 직무수행능력 부족이 퇴직사유라고 명시됨.
- 직무수행능력이 부족한 자에 대해 2개월 간 보직대기를 명할 수 있고, 위 기간 내 보직을 부여받지 못하면 인사위원회 심의를 거쳐 당연퇴직시킴.

② 평가: 지침이 요구하는 객관적·합리적 기준에 의한 공정한 평가가 있었는지 논란이 될 수 있음.

- 광고영업직 사원은 광고수주실적이 절대적 직무능력 판단자료인데, 입사 다음해부터 영업실적이 동료들에 비해 현저하게 떨어져, 2년간 영업실적이 최하위(1999년의 경우 동료직원들의 1/4에도 미치지 못함), 입사 다음해 인사고과평정도 최하위를 받음 → 지침이 요구하는 객관적·합리적 기준이었는지에 대해서 논란이 일어날 수 있음(예: 동종업계 평균 광고액 비교 등).
- 악성 미수금의 경우 실제 광고가 게재되었음에도 참가인들이 광고주로부터 어음조차 교부받지 않는 등 광고료 회수노력을 게을리 함 → 다른 직원들은 어음을 다 받았는지에 대한 비교도 없음.

③ 회피노력: 지침에서 요구하는 교육훈련, 배치전환 등 개선기회를 부여하지 않음.

- 다만, 보직대기발령 기간 동안 미수금 회수 및 광고수주실적 향상을 위한 방안 마련을 지시했으나 상기 근로자들이 이행을 하지 않음.
  * 근로자의 요청에 따라, 회사는 미수액 일부를 감액하고, 미수금 회수기간을 연장해주었으나, 근로자는 보직대기 기간 중 미수금 회수계획을 세우지 못하고 회수실적도 전무하며, 심지어 가족들이 운영하는 식당에 대한 광고료도 회사에 납입하지 아니함.
- 광고영업직 사원들에 대해 직무능력의 회복이나 근무태도 개선을 위한 교육훈련 또는 특별한 연구과제를 부여하는 것이 현실적으로 어려움 → 지침에서 요구한 사항을 충족하지 못함.

④ 대상자 선정: 상기 열거된 ①~③ 등을 고려하여 징계권 남용이 아니며, 대기발령이 정당하여, 사회통념상 근로관계 유지를 기대할 수 없는 것이라 판단

(2) OO방송(서울행법 2003구합39306)

① 사유: 업무능력 부족이 해고 사유라고 취업규칙, 단체협약에 규정됨.

- 2년 연속 인사고과에서 최하위 등급(C)을 받은 것은 취업규칙상 징계사유에 해당

② 평가: 지침에서 요구한 객관적·합리적 기준에 의한 공정한 평가였나에 대해 의문을 제기할 수 있음.

- 부서장의 1차 상대평가와 차상위 소속 부서장의 2차 평가를 종합하여 등급을 확정하고, 평가등급은 4등급(S~C)으로 되어있으나, C등급은 강제분포가 아닌 임의분포였기 때문에 법원은 정당하다고 인정함 → 지침에서 요구하는 4등급에 대한 객관적인 점수가 얼마인지 적시되지 않음.

③ 회피노력: 판결문에 교육훈련, 전환배치 등의 기회 부여에 대한 내용이 없음.

- 회사에서 별도의 교육훈련, 배치전환 등의 노력을 했다는 것이 판례에 언급되지 않음.

④ 대상자 선정: 상기 열거된 ①, ② 등을 통해 징계사유의 존부, 징계의 적정 여부, 징계절차의 하자 유무 등을 고려하여 사회통념상 근로관계 유지할 수 없게 되었다고 판단

(3) OO농업협동조합(서울행법 2005구합27871)

① 사유: 업무능력 부족이 해고 사유라고 취업규칙, 단체협약에 규정됨.

- ‘인사규정’에 직무수행능력의 현저한 부족으로 근무성적 또는 업무실적이 극히 불량한 때 면직가능하다고 명시됨.
- 근로자가 직무수행능력이 부족한 자에 대해 대기발령을 할 수 있고, 3개월이 경과하여도 직위를 부여받지 못하면 면직이 가능함.

② 평가: 지침이 요구하는 객관적·합리적 기준에 의한 공정한 평가는 없음.

- 다만, 대기발령 전력, 단순기계 조작미숙 등을 직무수행능력 부족으로 판단
  * 근로자는 업무수행능력 미숙으로 2회의 대기발령을 받은 전력이 있음.
  * 근로자는 단순한 주화포장 등의 업무조차 제대로 수행하지 못함.
  * 근로자가 업무를 제대로 처리하지 아니하여 민원제기를 받고, 동료직원들이 업무미숙을 이유로 해당 근로자의 업무배제를 건의함.

③ 회피노력: 업무습득기간 제공 등 교육훈련 기회는 부여했으나, 대기발령 이후 복직하면서 기존 업무와 다른 업무를 맡긴 것이 전환배치 등의 기회 제공인지에 대해 논란이 있을 수 있음.

- 회사는 근로자에게 업무를 중단하고 그 기간 동안 업무습득기간을 명하는 등 배려를 해주었으나 업무능력이 향상되지 않았음.
  * 1999년 대기발령 이후 농산물 직판장으로 전출되었고, 2002년 대기발령 이후에는 모출납업무, 자동화기기 관리업무 등을 담당하게 됨.
  * 근로자는 대기발령 기간동안 돈을 벌기위해 다른 곳에서 일하는 등 업무향상을 위한 구체적인 노력을 하지 않아 면직처분을 받음.

④ 대상자 선정: 상기 열거된 ①~③ 등을 통해 대기발령의 적법성, 면직처분의 적법성 등을 고려하여 사회통념상 근로관계 유지를 기대할 수 없게 되었다고 판단

3) 소결: 정부지침(초안)은 다양한 업종의 특성을 반영하지 않은 일반화된 해고지침이며, 이를 모두 충족하려면 현행보다 해고가 어려워 질 수 있음.

□ 산업현장에서 저성과자에 대한 해고는 통상해고가 아닌 징계해고 형태를 취하고 있었으나, 정부 지침은 개선을 보이지 않는 저성과자에 대해 ‘징계해고’가 아닌 ‘통상해고’ 할 수 있다고 밝힌 점이 의의임.

□ 정부 지침은 다양한 업종과 직업군의 해고 판례에서 적시한 해고 요건을 모두 충족하도록 하고 있으나, 이렇게 일반화해서 적용할 수 있는지 의문임 → 일반화된 요건을 모두 충족해야 한다면 기존 징계해고보다 통상해고가 더욱 어려운 것이 아닌가라고 생각하게 됨.

□ 업무부진자 해고를 두고 지노위, 중노위, 행정법원에서 엇갈린 판결을 내린 점에 비추어 사실관계 평가와 해석이 중요하다고 유추할 수 있는데, 과연 지침이 이러한 평가·해석에 얼마나 도움이 될지 미지수임.

2. 취업규칙 변경 지침(초안)은 근로자의 일방적 희생과 부담을 강요하는가?

1) 정부 지침(초안)은 기존에 '사회통념상 합리성' 요건을 인정한 판례에서 적시한 요건을 모두 충족한 임금피크제는 노동조합의 동의 없이 도입할 수 있다고 적시함.

○ 지침은 임금피크제 도입에 따른 '근로자 불이익 정도', '취업규칙 변경 필요성' 등의 판단기준을 고려하여, 감액률이 크지 않고 합리적인 임금피크제 도입은 '사회통념상 합리성'을 인정받을 수 있다고 설명

<취업규칙 변경 지침 - 사회통념상 합리성 판단>

판단기준	내 용
근로자 불이익 정도	▪ 임금피크제가 '정년 60세 의무화' 입법 취지를 유명무실하게 할 정도로 임금을 감액하지 않는다면 불이익이 크다고 보기 어려움
취업규칙 변경 필요성	▪ '정년 60세 의무화' 법은 노사 모두에게 임금체계를 개편해야 할 의무를 부여했으므로, 취업규칙 변경 필요성이 인정될 수 있음
변경된 취업규칙 내용의 상당성	▪ 임금피크제 적용연령, 적용후의 임금 수준이 동종기업 또는 사회 일반적인 기대 임금수준보다 낮지 않으면 인정됨
근로조건 개선 여부	▪ 임금피크제 도입에 따른 보상, 업무조정, 복리후생 제도 확대 등 다양한 근로조건 개선상황을 종합적으로 고려하여 판단
노동조합과 충분한 협의노력	▪ 사용자가 일방적으로 변경하면 합리성이 인정되기 어려움 ▪ 노조가 대안제시 없이 논의를 거부하면 합리성 인정
동종 사항에 관한 국내 일반적 상황 등	▪ 임금피크제 도입에 따른 취업규칙 변경 내용과 관련, 지역 내 동종 업계 등의 임금감액 비율, 대상 조치, 교섭 및 합의 경향 등을 고려

2) 취업규칙상 특정 제도를 변경하는 것이 '사회통념상 합리성'을 갖췄다고 법원이 인정한 판례들은 정부 지침(초안)에서 지적한 6가지 판단기준 등을 대부분 충족함.

<사회통념상 합리성 관련 판결>

No.	구분	선고일	사회통념상 합리성 여부	이유
1	한국OO연구원	'01.1.5	인정	▪ 정년이 10년이나 연장되었고, 다른 근로조건이 개선되었으므로 합리성이 인정됨
2	학교법인OO	'15.7.23	인정	▪ 최하위등급을 벗어나면 본래 연봉이 회복되고, 향후 10년 이내 신입생이 급감하여 경쟁력회복이 필요하므로 합리성이 인정
3	OO생활산업	'04.5.14	불인정	▪ 근로자들의 불이익에 따른 근로조건 개선 등 이익요소가 없으므로 인정 불가함
4	OO기반공사	'04.7.22	불인정	▪ 근로자들이 받을 불이익을 완화할 조치가 부족하므로 인정할 수 없음

(1) 사회통념상 합리성 인정 판례

○ 한국OO연구원(대법 99다70846): 조직 통합과정에서, 한국OO기기센터 출신 직원들과 기존 한국OO금속시험연구소 직원들 사이에 서로 다른 퇴직금지급률을 조정할 필요성이 높았던 점. 한국OO기기 직원들의 정년이 통합 후 55세에서 65세로 10년이나 연장된 점, 호봉이 조정되어 퇴직금 산정의 기초가 되는 임금이 인상되는 등 통합 후 다른 근로조건이 개선된 점 등을 고려하면 퇴직금지급규정이 직원들의 동의를 받지 않아도 될 만한 '사회통념상 합리성'이 있다고 봄이 상당함.

○ 학교법인OO(부산지법 2013가다21019): 교원업적평가에서 한번이라도 최하위 등급을 벗어나게 되면 본래의 연봉으로 회복된 점, 향후 10년 이내에 대학 신입생 수가 급격히 감소하여 경쟁력을 확보할 필요성이 있는 점, 연봉 삭감분 전액을 다른 교원들의 성과급으로 지급한 점 등을 고려할 때 '사회통념상 합리성'을 가진다고 보아야 함.

(2) 사회통념상 합리성 불인정 판례

○ OO생활산업(대법 2002다23185, 23192): 근로자들은 1998년 상여금뿐만 아니라

1999년 이후 상여금까지 삭감하는 것에 동의하였다고 볼 자료가 없고, 국가외환위기 상황에서 워크아웃 계획에 따라 상여금 규정을 개정한 것이더라도 근로조건 개선이라든지 기타 이익되는 요소 없이 상여금 조항을 삭제한 것은 '사회통념상 합리성'이 있다고 보기 어려움.

○ OO기반공사(대법 2002다59702): 인사규정개정 당시 농지개량조합, 농어촌진흥공사, 농지개량조합연합회 등 3개 기관의 통합 등 인사규정개정의 필요성은 수긍이 가지만, 정년 단축에 따라 바로 퇴직하게 될 근로자들에 대해 그 불이익을 완화할 수 있는 아무런 대상조치나 경과조치를 두지 않음으로써 근로자들이 받게 될 불이익이 크므로, '사회통념상 합리성'이 있다고 보기 어려움.

3) 소결: 취업규칙 불이익 변경 관련 판례에서 노조 동의를 얻지 않아도 되는 경우가 적어 실제 산업현장에서 지침이 유용하게 활동될지 의문

□ 취업규칙 변경제도 자체에 대한 문제 해결방안을 제시하지 않고, 임금피크제 도입에 국한하여 해결방안을 제시함.

□ '사회통념상 합리성'을 갖췄다고 인정된 판례가 소수여서, 산업현장에서 정부지침만을 믿고 노조 또는 근로자 과반수의 동의 없이 임금피크제를 일방적으로 도입하려는 기업은 거의 없을 것임.

토 론 문

홍준호 (김앤장 법률사무소 변호사)

신중한 검토 끝에 인력 조정을 둘러싼 제도적 불확실성을 제거하고 절차를 명확하고 규정하는 본건 지침을 마련하느라 애쓰신 관계자 분들께 경의를 표하면서, 본건 지침에 관하여 몇 가지 의견을 드림으로써 지정토론에 갈음하고자 합니다.

1. 업무능력 결여, 근무성적 부진 근로자에 대한 해고 관련

본 건 지침은 근무성적 부진 등을 이유로 하는 해고가 정당성을 인정받기 위한 요소로서, (1) 단체협약 또는 취업규칙 등에 업무능력 부족이 해고 사유에 해당함을 명확히 규정되었는지, (2) 객관적이고 합리적인 기준에 의한 공정한 평가가 이루어졌는지, (3) 교육훈련과 배치전환 등 개선의 기회를 부여하였는지, (4) 업무능력의 개선 가능성이 있는지 및 업무능력 부족으로 업무상 상당한 지정이 초래되었는지 등을 들고 있습니다.

- 그런데, 위 (1) 및 (2)의 판단요소와 관련하여, 사용자가 근로자를 근무성적이 부진하다고 평가하는 대상기간 이전에 이미 이러한 규정이 존재하고, 근로자들이 이러한 규정에 따른 객관적이고 합리적인 기준을 평가 대상기간 이전에 인식할 수 있는 상태에 놓여 있었다는 점도 지침에서 명확히 하는 것이 좋겠다는 의견을 드립니다.
- 또한 위 (2)의 판단요소와 관련하여, 근무성적이 부진하다고 판단 받은 근로자에 대한 평가가 공정해야 한다는 점뿐만 아니라, 그러한 평가가 단기간의 일시적인 근무성적 저조가 아니고, 장기간에 걸쳐 수차례의 평가과정 속에서 근무성적불량이 계속되는 경우에 해당되어야 한다는 점도 명시되는 것이 합리적이라는 의견을 드립니다(서울고법 2005. 7. 7. 선고 2004누14597 판결).

2. 업무능력 결여 등에 따른 통상해고의 절차 관련

본 건 지침은, 업무능력 결여 등에 따른 해고시 정당성 판단의 핵심요소로 '평가의 신뢰성'을 들면서, 평가위원회 등 복수의 평가자를 두거나 여러 평가단계를 두면 결과의 타당성을 높이고, 근로자가 이의 제기할 수 있는 절차를 두면 신뢰성을 제고할 수 있다고 설시하고 있습니다.

- 제가 업무능력 결여 등에 관련된 해고무효소송 또는 부당해고구제신청 사건 등의 소송대리인으로서 소송수행을 해 본 경험에 의하면, 위와 같은 본건 지침의 내용은 재판부 또는 노동위원회의 대체적인 견해와 태도에 부합하는 것으로서, 적절한 설명으로 보입니다.

3. 평가방법의 타당성 관련

본 건 지침은, 업무능력 결여에 따른 통상해고 정당성 관련 구체적 기준과 절차에 대해 설명하면서, '평가방법의 타당성'에 관하여, 계량평가(영업실적 등 객관적 수치로 업무능력이나 성과가 나타남)나 절대평가(개인별 일정 목표를 정해놓고 달성 여부를 평가) 방식이 객관성과 합리성을 제고할 수 있으며, 불가피할 경우 비계량, 상대평가가 활용될 수 있으나 계량평가•절대평가 방식과 결합하여 상호 보완하는 것이 바람직하다고 설명하여, 계량평가와 절대평가 방식에 큰 무게를 두고 있습니다.

- 그런데, 타당한 평가방법은 근로자가 수행하는 업무의 종류(사무직/ 생산직), 근로자의 법적 지위(정규직/ 기간제/ 파견), 근무시간(풀타임/ 파트타임), 근로자가 수행하는 업무의 성격 등에 따라 상당히 달라질 수 있는데, 계량평가와 절대평가에만 크게 무게를 두는 설명은 오해를 불러 올 수도 있는 부적절한 면이 있습니다. 예를 들어, 상당한 정도의 판단과 창의성을 요하는 업무를 수행하는 근로자의 경우에는 업무목표 달성을 수치화 하기 어려워서 계량평가를 한다는 것 자체가 불가능하고 또한 일정한 목표를 정해 두기 어렵기 때문에 절대평가도 어려울 것입니다. 물론 무단결근 여부, 근무시간 준수 등의 기초적 근무태도와 같은 일부 사항은 계량평가 및 절대평가가 가능할 수도 있습니다만, 업무의 핵심적인 부분에 대한 평가가 주요한 판단 기준이 되어야 할 것입니다. 물론 본건 지침에서도 기업조직에의 융화 정도 등 주관적인 평가가 일부 포함되어 있다고 해서 부당하다고 단정하기 어렵다고 설명하는 부분도 있으나, 상대평가에 대해서는 의무적인 일정인원 할당 방식은 합리성을 인정받기 어렵다고 단정적인 설명을 하기도 합니다. 따라서, 평가방법에 대해서는 "위에서 말씀 드린 근로자가 수행하는 업무의 종류 등 여러 경우에 따

라서 적절한 평가방법으로 판단될 수 있겠으나 일반적인 경우라면 계량평가와 절대평가가 더 합리적인 방법으로 판단될 가능성이 높다” 정도의 설명이 적합하지 않을까 합니다.

4. 취업규칙의 불이익 변경 관련

본 건 지침은, 취업규칙을 변경함에 있어서 여러 개의 근로조건을 동시에 개정하는 경우 하나의 근로조건을 이루어 서로 대가관계나 연계성이 있는 경우 종합적으로 판단해야 하는데, 임금피크제는 정년 연장과 별개의 근로조건이므로 그 자체로 불이익한 변경이라는 취지로 설시하고 있습니다.

- 그런데 임금피크제를 실시하면서 그와 대가관계가 있고 연계성이 있는 것으로 보이는 시스템의 변화를 동시에 실시하는 경우가 있는데, 이러한 경우에 대해서도 지침에 설명이 있으면 좋겠다는 의견입니다. 대법원 판례에서 취업규칙을 변경할 때 새로운 수당을 신설하면서 이를 퇴직금 산정의 기초에서 제외하는 경우에는 수당 신설과 퇴직금 산정기초의 범위를 조정하는 두 가지의 변경사항을 종합해 볼 때 근로자에게 불이익이 없다고 판단하였듯이, 예컨대 임금피크제를 실시하면서 동시에 새로운 수당을 신설하여 근로자들에게 일정한 경제적 이익을 부여하는 경우에는 그 이익과 불이익의 정도를 형량해서 불이익 변경 여부를 판단할 수 있을 것으로 보입니다.

5. 고용 과정에서의 합리적인 제도운용

근로자 채용의 단계에서 시용제도를 운용하거나 기간제근로자를 정규 근로자로 채용함에 있어서, 정식 채용을 거절하는 경우의 사유는 정규 근로자를 해고할 때의 정당한 이유보다는 넓게 인정된다는 것이 판례의 입장입니다. 즉, 대법원 판례는, 시용계약을 일정 기간 동안 근로자가 앞으로 담당하게 될 업무를 수행할 수 있는가에 관한 그 인품 및 능력 등을 평가하여 정식사원으로서의 본채용 여부를 결정하는 것이라고 정의하면서 이러한 시용계약에 있어서 시용기간 중에 있는 근로자를 해고하거나 시용기간 만료 시 본 계약의 체결을 거부하는 것은 사용자에게 유보된 해약권의 행사로서 당해 근로자의 업무능력, 자질, 인품, 성실성 등 업무 적격성을 관찰·판단하려는 시용제도의 취지·목적에 비추어 볼 때, 그 정당성 여부는 보통의 해고보다는 넓게 인정되어야 한다는 견해를 제시하고 있습니다(대법원 2006. 2. 24. 선고 2002다62432 판결). 사용자가 보다 많은 근로자와 직접적으로 함께 일해 본 뒤

에 그 회사조직 자체 및 담당 업무의 특성과 성격에 적합한 근로자를 선택할 수 있는 길을 보다 넓게 열어 주는 것이 취업률의 제고에 도움이 된다는 점을 고려할 때 시용제도와 기간제근로계약의 활용을 보장해 주는 것도 노동시장 활성화에 도움이 될 것입니다. 따라서 시용근로자의 채용거절 및 기간제근로자의 정식채용거절의 경우 그 사유의 정당성을 다소 유연하게 허용하는 제도적 뒷받침이 있는 것이 바람직하다는 의견을 드립니다.

keri 한국경제연구원
07320 서울시 영등포구 여의대로 24 전경련회관 45층
T. 02-3771-0076 F. 02-785-0272